

CAPÍTULO 10

EQUIDAD

Marta R. Vigevano

1. La equidad a través de la historia

La noción de equidad se remonta varios siglos atrás en la historia, enraizada en el pensamiento filosófico, moral y jurídico.

En Grecia, el concepto de equidad —denominada *epieikeia*— va a ser desarrollado, esencialmente, por los filósofos Platón y Aristóteles. Para Platón, la equidad era una fuerza externa a la ley¹. Por su parte, Aristóteles realiza la primera exposición sistémica de la *epieikeia* en su *Retórica* al elaborar una distinción entre justicia escrita y no escrita. Según sus enseñanzas, la equidad se da algunas veces sin el consentimiento del legislador, ya sea cuando no se ha legislado sobre una cuestión o cuando una ley de carácter general no puede aplicarse a situaciones concretas. Algo puede llegar a ser injusto por la aplicación de la ley escrita pero justo en la realidad de los hechos, y esto es precisamente el carácter equitativo. Estas ideas aristotélicas van más allá de los límites del derecho positivo y se integran al concepto de justicia como virtud².

Decía Aristóteles que entre el derecho y la equidad se puede establecer una relación de interdependencia. El concepto de *epieikeia* en los griegos se interpreta como una justicia individualizada, aplicada a un caso concreto. La equidad tiende a mitigar los inconvenientes que una ley general puede traer aparejados³. Lo que plantea es que lo equitativo, siendo justo, no siempre es lo justo según la ley, sino debe ser la regulación de lo justo legal⁴.

Herodoto, al igual que Tucídides, utiliza el término *epieikeia* en el sentido de lo específicamente justo en oposición a la justicia abstracta. Para los filósofos e historiadores griegos, la equidad es la adaptación de la ley a las singularidades, es decir, la corrección de la ley general con relación a una cuestión específica⁵.

La noción romana de *aequitas*⁶ tiene tres significados destacables: se la entiende como complemento del derecho, como principio configurador del derecho y como principio exagético de la ley.

1 Vinuesa, Raúl E., "The new role of equity as a source of international law", en *Sources of International Law, Thesaurus Aeneasium*, vol. XIX (1992), Institute of Public International Law and International Relations of Thessaloniki (Grecia), p. 488.

2 Uscatescu Barrón, Jorge, "Acercas de un concepto romano: aequitas. Un estudio histórico-conceptual", *Cuadernos de Filología Clásica. Estudios latinos*, Editorial Complutense, Madrid, n.º 8 (1998), pp. 78-108.

3 Falcón y Tella, María José, *Equity and Law*, traducción al español por Muckley, Peter, Martinus Nijhoff, Leiden, 2008, pp. 17-18.

4 Aristote, *Éthique à Nicomaque*, traducción y presentación por Bodéüs, Richard, GF Flammarion, París, 2004, pp. 234-238.

5 Homero —en *La Iliada* y *La Odisea*—, Sófocles, Esófodo, Demóstenes, entre otros, utilizan el término en el mismo sentido.

6 El término *aequitas* es un sustantivo derivado del adjetivo *aequus*, una de cuyas acepciones significa equilibrado.

En el derecho romano se introduce un procedimiento a través de la *lex Aebutia*⁷ por el cual el pretor –magistrado romano encargado de aplicar el derecho civil– trataba de contrarrestar los excesos del formalismo jurídico y permitía completar el derecho civil adaptándolo a las nuevas circunstancias económicas y sociales. Con esta intervención, el pretor restablece una situación eliminando la desigualdad que se planteaba en la realidad contra la cual el *ius civile* nada preveía.

Con Cicerón, el derecho romano reafirma la *aequitas* como una virtud distinta de la justicia. Para este jurista, político, filósofo, escritor y orador romano la rigurosa aplicación de la ley podía ser una fuente de injusticia –*summum ius, summa iniuria*–. Cicerón es quien coloca la *aequitas* entre las fuentes del derecho, diferente de las leyes. Esto se refleja también en otros juristas, como Paulo, que adopta el término *semper bonum et aequum*, en el sentido de aquello que se ajusta a lo correcto, un restablecimiento de lo igual tras una situación de desigualdad o iniquidad. Esta acepción de *aequitas* no se contraponen, sino que se equipara a la de *ius*. El derecho romano presenta una constante relación, y en algunas oportunidades confrontación, entre el *ius strictum* y el *ius aequum*⁸.

En este proceso, va a ser el emperador Constantino quien invoque la *aequitas* como un medio de amoldar el *ius civile* a las nuevas exigencias del Cristianismo. En esta instancia, la *aequitas*, al contraponerse a la ley escrita, se identifica en cierta medida con una justicia natural válida para todos los hombres.

En la perspectiva canónica, el concepto de equidad se asimila al de *humanitas*, que implica la aplicación de la moderación, la caridad, la piedad y la benevolencia. Durante el Cristianismo la equidad se nutre de sus dogmas y creencias y su función es considerada *iustitia dulcore misericordiae temperata* (la justicia atemperada por la dulzura de la misericordia). La equidad en ciertos casos puede corregir y superar el “justo legal”, pero no lo “justo”, e implica, en muchas ocasiones, la idea de justicia, benignidad, misericordia y caridad. La equidad es el punto medio entre el rigor y la dispensa⁹.

Para Santo Tomás, la equidad es una parte de la virtud de la justicia, dice: “El que en caso de necesidad obra sin atenerse a las palabras de la ley no enjuicia la ley misma, sino un caso particular en el que ve que las palabras de la ley no pueden guardarse”¹⁰, y luego agrega que “lo bueno es, dejando a un lado la letra de la ley, seguir lo que pide la justicia y el bien común. Y a esto se ordena la epiqueya, que entre nosotros se llama equidad”¹¹.

Para el concepto medieval, la equidad es un modo de interpretación del texto con el fin de poder desentrañar su espíritu. Expresaba Calvino que la ley moral de Dios no es otra cosa que un testimonio de la ley natural y el principio de la equidad entero está en ella contenido¹².

Para Grocio, la equidad es la virtud de enderezar aquello en que la ley, a causa de su generalidad, ha fallado¹³.

En el sistema anglosajón, a pesar de que no tiene como antecedente el derecho romano, surge hacia el siglo XI la figura del canciller (*chancellor*), análoga a la del pretor romano. Las normas rígidas y formales fueron mitigadas a través de los *writs*, que empezaron siendo una forma de justicia “natural” que permitía que cada caso concreto fuese adecuado a las circuns-

7 La Ley Aebutia entre los años 150 y 120 a.C. introdujo el sistema formulario, en el ámbito procesal civil, limitando el rígido procedimiento de las *legis acciones*, el cual comenzó a declinar y fue sustituido progresivamente por este, menos solemne, y que no era totalmente oral como su predecesor, sino que contaba con una parte escrita.

8 Falcón y Tella, María José, *op. cit.*, pp. 25-35.

9 Baura, Eduardo, “Interpretación de la ley y la equidad canónicas en el arte jurídico”, en *Ius et Iuria. Escritos de Derecho Eclesiástico y de Derecho Canónico en Honor del Profesor Juan Fornés*, María Blanco, Beatriz Castillo y otros (eds.), Editorial Comares, Granada, 2010, pp. 87-101.

10 Santo Tomás de Aquino, *Suma de Teología II, Parte I-II*, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2.ª edic., 1994, p. 754.

11 *Ibid.*, IV Parte II-II (a), p. 293.

12 Calvin, John, *Institutes of the Christian religion*, traducido por Beveridge, Henry, Edimburgo, 1845 (disponible en <http://www.unige.ch/theologie/cite/calvin/sites.html>).

13 Moratell Villa, Sergio, “Filosofía del derecho internacional: Suárez, Grocio y epígonos”, *Revista Internacional de la Cruz Roja*, 30/09/1997 (disponible en <http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdlbc.htm>).

tancias particulares por medio de un sistema de jurisprudencia de equidad. Se constituye de esta forma un cuerpo de normas positivas por las cuales se establecen las condiciones bajo las cuales el *writ* sería concedido o denegado.

Con el correr del tiempo, la acción jurisdiccional resultó insuficiente para resolver los nuevos problemas planteados con relación al cambio de las circunstancias, por ello el Parlamento autorizó al canciller a que, en casos análogos, aplicara nuevos *writs* sobre el modelo de los antiguos. La acción del canciller llegó a suplir ciertos preceptos del *common law* mediante la *equity*, a los efectos de superar las lagunas motivadas por la rigidez y corregir los abusos, consecuencia de aquel.

Hoy en día en el derecho inglés la equidad –*equity*– se entiende como el sistema jurisdiccional propio, derivado de la discrecionalidad de los jueces y árbitros a la hora de aplicar consideraciones generales de justicia a las controversias jurídicas (*equity jurisprudence*)¹⁴.

La mayoría de los grandes sistemas jurídicos del mundo hacen referencia a la equidad, así lo constata el juez Fouad Ammoun en su opinión individual en el caso de la *Plataforma Continental del Mar del Norte*, al mencionar en el derecho musulmán la *Istihsan*¹⁵; en el derecho chino, la primacía de la ley moral y del sentido común de la equidad; en el derecho hindú, la invitación al juez a decidir conforme a la justicia; en los derechos de los países africanos y asiáticos, la costumbre que determina que los jueces no deben apartarse de la equidad¹⁶.

2. La equidad en el derecho internacional

2.1. Concepto de equidad

La noción de equidad no ha sido un concepto fácil de acuñar en el derecho internacional. Podemos destacar algunas acepciones, tales como: a) la equidad como base de una justicia individualizada para atemperar los rigores de la ley; b) la equidad considerada como equilibrio, racionalidad y buena fe; c) la equidad como fundamento de ciertos principios del pensamiento jurídico vinculados a la justicia y la razonabilidad; d) la equidad como medio para establecer una justicia distributiva¹⁷.

También ha sido considerada como un medio para apoyar el derecho, pero que algunos autores consideran que ha ido virando hacia un proceso que consiste en descartar el derecho y, de ese modo, facilitar las conclusiones apropiadas para llegar al fin perseguido. La crisis que se produce en la estructura normativa del derecho internacional hace que ciertos conceptos, fuera de lo que es la norma jurídica como fuente, adquieran un rol creciente y la equidad se constituye en principal actor de este proceso¹⁸.

14 El derecho inglés es esencialmente un sistema de casos (*case law*) y las fuentes son: a) el derecho creado por los jueces –*judge made law*–; b) el derecho consuetudinario –*customary law*– que abarca los usos tradicionales adoptados por los tribunales; c) las sentencias judiciales –*judicial decisions*– emanadas de los jueces, y d) la *equity* como un sistema jurisdiccional propio. Ver Shaw, Malcolm, *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 5.ª edic., 2008, pp. 120-128.

15 En la ley islámica, la noción de *istihsan*, inspirada en el principio de justicia y conciencia, es la más cercana a la de equidad. Presupone partir de una norma de derecho cuya aplicación trae como consecuencia resultados injustos, pero poniendo énfasis en garantizar la integralidad y la coherencia entre el texto y el objetivo de la *Sharia* (cuerpo de derecho islámico), ya que uno no puede ser leído en forma aislada del otro.

16 *Plataforma Continental del Mar del Norte* (República Federal de Alemania/Dinamarca; República Federal de Alemania/Países Bajos), CIJ, Fallo, 20/02/1969, *CIJ Recueil* 1969, Opinión individual de M. Fouad Ammoun, pp. 139-140, parágrafo 38.

17 Schachter, Oscar, “International law in theory and practice: general course in public international law”, *R.C.A.D.I.*, vol. 178 (1982-V), pp. 82-83.

18 Well, Prosper, “Towards Relativity in International Law?”, *A.J.I.L.*, vol. 77 (1983), p. 413.

Se plantea así una oposición entre aquellos que buscan obtener un resultado más allá de la norma jurídica (instrumentalistas) y los que buscan la aplicación de la equidad en armonía con el derecho (positivistas)¹⁹.

La equidad es, en realidad, una cualidad del derecho que guía en cierta medida su interpretación, sin descartar las normas. Admitir que consideraciones de equidad pueden conducir a dejar de lado las reglas de derecho sería contrario al principio de seguridad jurídica. Estas consideraciones podrían inspirar las reivindicaciones políticas que en su momento, quizás, sean el origen de nuevas normas jurídicas, pero la equidad no puede sustituir al derecho positivo, salvo en el caso de que las partes en litigio así lo consientan²⁰.

Podríamos decir que el concepto de equidad puede ser incluido dentro del marco de dos concepciones. Por una parte, es un método de conciliación de normas de derecho internacional aplicables a una cuestión determinada que permite arribar a una situación justa para las partes y, por la otra, se la puede considerar como un sistema destinado a mitigar las deficiencias del derecho positivo.

La equidad se instala en el marco de la aplicación de las normas, en los sistemas jurídicos nacionales y en el internacional. El Institut de Droit International ha manifestado que la equidad es inherente a una sana aplicación del derecho²¹. En el mismo sentido, la Corte Internacional de Justicia en el caso *Barcelona Traction*²² estimó que, en el ámbito de la protección diplomática, como en todos los otros, el derecho internacional exige una aplicación razonable.

El derecho tradicionalmente tiende a crear una situación de certitud y de seguridad de la norma positiva, pero coexiste también con la necesidad, frente a nuevas situaciones cada vez más específicas, de buscar a través de la equidad una justicia que se adapte a los casos concretos²³.

Podemos plantear, también, el análisis de la noción de equidad incorporando los valores de la equivalencia y de la proporcionalidad. La equivalencia no presupone la aplicación de la equidad solo a aquellas cuestiones de igual naturaleza, sino a una multiplicidad de situaciones distintas. El sentido de la equivalencia radica en la identidad de tratamiento de los casos diferentes²⁴.

En cuanto a la proporcionalidad, en la jurisprudencia se ha mencionado en varias oportunidades este elemento, sobre todo en el contexto de la utilización, por los Estados, de los espacios marítimos. Por ejemplo, en el caso de la *Plataforma Continental entre Túnez y Libia*²⁵, la CIJ consideró que, para satisfacer el criterio de proporcionalidad como aspecto de la equidad, al delimitar la plataforma continental se debían tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes. No se debe buscar un método único de delimitación, el problema es definir los medios por los cuales la delimitación puede ser fijada de manera de ser reconocida como equitativa. La función de la proporcionalidad es comprobar el carácter equitativo, ya sea del método empleado, ya sea de un factor geográfico o físico, en particular utilizado en la instrumentación del método determinado.

Otro aspecto interesante para destacar es que la equidad no presupone necesariamente igualdad. En la opinión consultiva emitida por la Corte Permanente de Justicia Internacional

en el caso de las *Escuelas Minoritarias de Albania*, se expresó que la igualdad en derecho excluye toda discriminación, pero que la igualdad en los hechos puede requerir que sea necesario un tratamiento diferente con el fin de arribar a un resultado que establezca el equilibrio entre situaciones diferentes²⁶. Por ello es necesario que exista una igualdad de hecho y no solo una igualdad formal de derecho en el sentido de que los términos de la norma eviten establecer un tratamiento diferente.

En un sentido similar, la CIJ, en el caso de la *Plataforma Continental del Mar del Norte*, determinó que el rol de la equidad no engendra necesariamente igualdad de tratamiento, sino que tiende a remediar de manera conveniente los efectos inequitativos de una situación o característica geográfica²⁷. La equidad no puede implicar que a un Estado sin acceso al mar pueda otorgársele una plataforma continental, ni tampoco que se pueda igualar la situación de un Estado con costas extendidas con la de un Estado con costas reducidas.

El significado jurídico de la equidad debe establecerse teniendo en cuenta la relación que se entabla entre las distintas instancias de la vida social y la coexistencia de diversos intereses que deben ser jurídicamente protegidos. Como expresa un importante jurista, la equidad permite regular la aplicación de la regla de derecho en función de situaciones concretas e individuales y de asegurar, en definitiva, la humanización del derecho²⁸.

La contribución de la equidad dentro del marco del derecho consiste en identificar el origen y la razón que justifica su aplicación a una controversia; el límite de esta adaptación está dado por la imposibilidad de ejercer una función creadora del derecho²⁹.

2.2. Funciones de la equidad: *infra legem*, *praeter legem*, *contra legem*

Se ha considerado, en general —en la doctrina y en la jurisprudencia—, que la equidad tiene tres funciones: correctora, complementaria o supletoria. La equidad podría ya sea atenuar la rigidez de la regla jurídica, completarla o suplirla. En el primer caso, se manifiesta *infra legem*; en el segundo, *praeter legem*, y en el tercero, *contra legem*³⁰.

La equidad no puede concebirse fuera del derecho ni constituirse en una fuente autónoma dando lugar a una regla diferente en cada caso que se la invoca pues, de lo contrario, nos enfrentaríamos a un contenido indefinido y contingente del derecho.

Referente a la función *infra legem* de la equidad, se puede decir que su característica principal reside en el hecho de que está dentro de la aplicación normal del derecho positivo, y que permite al juez elegir la interpretación más razonable a la luz de las circunstancias de un caso, con el fin de atenuar las consecuencias demasiado rigurosas del *summun ius*. Se produce así la adaptación de la regla jurídica a las circunstancias del caso concreto a fin de armonizar los intereses. Cuando un juez dicta una sentencia, si bien su fundamento radica en las reglas de derecho positivo, en muchas ocasiones se ve en la necesidad de adaptar esas reglas³¹. Así, la CIJ en el caso del *Canal de Corfú*³² invocó la equidad para evaluar el perjuicio causado por Albania a Gran Bretaña. En el asunto de la *Barcelona Traction*, si bien la CIJ en su fallo no tomó en cuenta ciertos principios equitativos a la luz de su evolución a través del tiempo, la opinión individual del juez Sir Gerald Fitzmaurice destacó la influencia e importancia de la evolución

19 Orrego Vicuña, Francisco, "Le pôle du Chancelier continue de s'allonger. Les principes généraux et la équité en droit international", en *Perspectives of International Law in 21st Century. Liber Amicorum Professor Christian Dominicé. In honour of his 80th Birthday*, Kohen, Marcelo; Kolb, Robert y Tehindrazana, Djacoba Liva (eds.), Martinus Nijhoff, Leiden, 2013, p. 79.

20 Daillier, Patric y Pellet, Alain, *Droit International Public*, LGDJ, París, 2002, pp. 354-356.

21 El Institut de Droit International, creado en 1873, es una institución dedicada al estudio del desarrollo del derecho internacional. Esta manifestación fue realizada en la sesión llevada a cabo en Luxemburgo el 09/09/1987 (disponible en http://www.idi-ili.org/idiF/resolutionsF/1987_lux_02_fr.pdf).

22 *Barcelona Traction Light and Power Company* (Belgica e. España), CIJ, Fallo, 05/02/1970, *CIJ Recueil* 1970, p. 44, parágrafo. 78-79.

23 De Visscher, Charles, *De l'équité dans le règlement arbitral ou judiciaire des litiges de droit international public*, Pédono, París, 1972, prefacio.

24 Rauter, Paul, "Quelques réflexions sur l'équité en droit international", *Revue Belge de Droit International*, vol. 15 (1980), p. 169.

25 *Plataforma Continental* (Túnez/Jamahiriyá Árabe Libia), CIJ, Fallo, 24/02/1982, parágrafo. 103, 130-131.

26 *Escuelas minoritarias de Albania*, CPJI, Opinión Consultiva, 06/04/1935, *PCIJ Serie A/B*, n.º 64, p. 19.

27 *Plataforma Continental del Mar del Norte*, doc. cit., pp. 80-81.

28 Bardonnat, Daniel, "Équité et frontières terrestres", *Mélanges offerts à Paul Reuter. Le droit international: unité et diversité*, Pédono, París, 1981, pp. 41-42.

29 Orrego Vicuña, Francisco, op. cit., pp. 69-68.

30 Dogan, Vindimir Djuro, *L'équité et le droit international*, Martinus Nijhoff, La Haya, 1963, p. 25.

31 De Visscher, Charles, "Cours Général des principes du Droit international", *R.C.A.D.I.*, vol. 86 (1954-II), p. 540.

32 *Canal de Corfú* (Reino Unido e. Albania), CIJ, Fallo, 15/12/1949, *CIJ Recueil* 1949, p. 249.

histórica de la equidad, concebida como un principio de moderación y de humanización de la norma jurídica³³.

En el caso de la *Delimitación marítima en el área entre Jan Mayen y Groenlandia*, la opinión individual del juez Weeramantry examinó el rol especial de la equidad en el razonamiento y conclusiones de la Corte. Se centró en la relevancia que tuvieron en la sentencia los principios de equidad, los procedimientos equitativos, los métodos equitativos y los resultados equitativos y destacó, en especial, que la equidad que operó en este caso lo hizo través de su función *infra legem*. En virtud de ello, planteó que la incertidumbre que pudiese generar la aplicación de la equidad en la delimitación marítima no constituía una razón suficiente para rechazar su aplicación en este caso en particular, ni para el desarrollo del derecho del mar en general³⁴.

En el caso *Burkina Faso/Mali*³⁵, la Sala de la CIJ se cuestionó si era posible aplicar la equidad sobre la cual ambas partes manifestaron opiniones divergentes. Se aclaró que la Sala no podría expedirse *ex aequo et bono* porque las partes no lo solicitaron. Por lo tanto, se tendría que tener en cuenta la equidad *infra legem*, es decir, la función de la equidad que constituye un método de interpretación del derecho vigente, y que, por lo tanto, necesariamente se basa en el derecho. La Corte, en la práctica, al recurrir a esta función de la equidad confirmó que su aplicación deriva de los principios y normas jurídicas que se encuentran en vigor.

En el caso de los *Indios Cayugas*³⁶, el Tribunal Arbitral consideró, teniendo en cuenta la aplicación de la equidad y basándose en un principio elemental de justicia, que era necesario considerar la sustancia y no limitarse al formalismo de la aplicación del derecho. La función de la equidad es servir como principio correctivo, en los casos excepcionales, para atemperar el rigor excesivo del derecho que conduciría a resultados injustos³⁷.

En los casos del *África Sudoccidental*, la CIJ sostuvo que los principios morales pueden tenerse en cuenta si encuentran amparo o medida en una forma legal³⁸. Además, señaló que la Corte no actúa como órgano legislativo, su función es aplicar la norma y no crearla. La Corte estaba autorizada a llenar lagunas aplicando la interpretación a través de la cual debía dar a los instrumentos su máximo efecto con el objeto de garantizar el logro de sus principios fundamentales.

Por otra parte, en varias sentencias arbitrales relacionadas con la reparación de daños, intereses y costos³⁹, se plasmó la necesidad de recurrir a la equidad como una forma que per-

mita al árbitro desempeñar su función, ya que, si no se hubiese basado en ella, no habría podido resolver la cuestión⁴⁰.

Podemos mencionar también el caso de las *Zonas francas de la Alta Savoya y de los Países de Gex*⁴¹, en el cual la CPJI analizó si el régimen establecido en la zona podía ser afectado solo por los términos del Tratado de Versalles o por consideraciones de equidad. Teniendo en cuenta que el acuerdo entre Francia y Suiza no contenía ninguna referencia a una decisión *ex aequo et bono*, la Corte mayoritariamente decidió la aplicación de la equidad dentro del marco estricto de la ley.

La equidad *praeter legem* cumple su función en el supuesto en que una regla jurídica no puede ser aplicada a un caso concreto porque resulta insuficiente. Es un medio de colmar las lagunas del derecho positivo. Así, la equidad puede constituir un aspecto subsidiario del derecho internacional. Aun cuando no exista una norma jurídica sobre una cuestión determinada, es necesario tomar una decisión por parte del juez y la equidad constituye una guía. El poder discrecional del juez —ante la inexistencia o insuficiencia de normas— se ejerce de una manera disciplinada: la función *praeter legem* es la aplicación del derecho mismo.

En la sentencia arbitral respecto de la responsabilidad de Alemania por los daños provocados a las colonias portuguesas, se estableció que, en defecto de reglas del derecho de gente aplicables a los litigios, los árbitros estiman que se deben superar las lagunas del derecho a través de la equidad, siempre dentro del derecho de gentes, aplicando la analogía y teniendo en cuenta su evolución⁴².

En el caso de la *Plataforma Continental del Mar del Norte*, la CIJ resolvió que el empleo del método de delimitación de la equidistancia no era obligatorio, que ningún otro método único de delimitación era obligatorio en todas las circunstancias y que la delimitación debía hacerse por acuerdo de conformidad con principios equitativos y teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes⁴³. El juez Ammoun, en su opinión individual, concordante con lo manifestado, planteó la pertinencia de recurrir a la equidad *praeter legem* para una mejor aplicación de los principios y normas de derecho. En el caso de la *Jurisdicción en materia de pesquerías*⁴⁴, la CIJ declaró que no existía dificultad en encontrar una solución equitativa, porque una solución de ese carácter deriva de la aplicación de la ley.

Hacemos notar que, en el caso de la disputa entre Canadá y Estados Unidos respecto de la *Delimitación Marítima en el Golfo de Maine*, la CIJ adoptó una orientación alejada de la postura que sostenía en los anteriores casos resueltos. En este fallo se concibe una solución equitativa independiente de una norma de derecho⁴⁵. Este razonamiento fue criticado por el juez Gros en su opinión disidente⁴⁶.

Los asuntos posteriores resueltos por la CIJ sobre delimitación marítima retoman la función de la equidad *praeter legem* como un método correctivo de las normas del derecho internacional y no sustituto⁴⁷. En el caso de la *Plataforma Continental Libia/Malta*, expresó la CIJ que la equidad es una emanación de la justicia, pero no una justicia abstracta, sino una justicia acorde con el derecho; de esta forma se puede lograr consistencia y un grado de previsible⁴⁸. En el caso de la *Plataforma continental Túnez/Libia*, la CIJ manifestó que la equidad es un

33 *Barcelona Traction*, doc. cit., p. 85. El juez Fitzmaurice para justificar esta argumentación cita un extracto de la obra *Snell's Principles of Equity*, de R. L. Megarry y F. W. Baker, 26.ª edic., 1966, pp. 5-8, que a continuación reproducimos: "Equity is that body of rules or principles which form[s] an appendage or gloss to the general rules of law. It represents the attempt . . . of the . . . legal system to meet a problem which confronts all legal systems reaching a certain stage of development. To ensure the smooth running of Society it is necessary to formulate general, rules which work well enough in the majority of cases. Sooner or later, however, cases arise in which, in some unforeseen set of facts the general rules produce substantial unfairness. When this occurs, justice requires either an amendment of the rule or, if . . . the rule is not freely changeable, a further rule or body of rules to mitigate the severity of the rules of law".

34 *Delimitación marítima de la zona situada entre Groenlandia y Jan Mayen* (Dinamarca c. Noruega), CIJ, Fallo, 14/06/1993, Opinión individual del Juez Weeramantry, párrs. 69-79.

35 *Disputa Fronteriza (Burkina Faso/Mali)*, CIJ, Fallo, 22/12/1986, párrs. 27-28.

36 *Indios Cayuga (Gran Bretaña) c. Estados Unidos*, Laudo Arbitral, 22/01/1926, R.I.A.A., vol. VI, p. 180. En este caso, Gran Bretaña demandó a los Estados Unidos por la indemnización debida a los indios Cayugas que se habían visto en la necesidad de abandonar sus territorios ubicados en la región de Nueva York por un acuerdo firmado entre ese Estado y los indígenas. En razón de la guerra entre Gran Bretaña y Estados Unidos en 1812, parte de los Cayugas emigraron a Canadá y este grupo se consideraba con derecho a seguir recibiendo la indemnización convenida como lo hacían los integrantes que habían quedado en el territorio de los Estados Unidos, según fijaba el acuerdo. La Corte Arbitral consideró que, si se aplicaba el derecho estricto, sería inequitativo para quienes estaban en Canadá.

37 *Georges Pinson (Francia) c. Estados Unidos Mexicanos*, Decisión n.º 1, 19/10/1928, R.I.A.A., vol. V, pp. 327 y 365.

38 *África Sudoccidental* (Etiopía c. Sudáfrica; Liberia c. Sudáfrica), CIJ, Fallo, 18/07/1966, ICJ Reports 1966, p. 48.

39 *Reclamos de armadores noruegos* (Noruega c. Estados Unidos), Laudo, 13/10/1922, R.I.A.A., vol. I, pp. 307-346, entre otros casos.

40 Akehurst, Michael, "Equity and General Principles of Law", *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 25, n.º 4 (1976), p. 803.

41 *Zonas Francas de la Alta Savoya y de los Países de Gex* (Francia c. Suiza), CPJI, Providencia, 19/08/1929, CPJI Serie A, n.º 22.

42 *Responsabilidad de Alemania por los daños causados en las colonias portuguesas del sur de África (sentencia sobre el principio de la responsabilidad)* (Portugal c. Alemania), Sentencia Arbitral, 31/07/1928, R.I.A.A., vol. II, pp. 1011-1033.

43 *Plataforma Continental del Mar del Norte*, doc. cit., p. 141.

44 *Jurisdicción en materia de pesquerías* (República Federal de Alemania c. Islandia; Reino Unido c. Islandia), CIJ, Fallo, 25/07/1974, ICJ Reports 1974, p. 38, párr. 78; p. 202, párr. 69.

45 *Delimitación de la frontera marítima en la región del Golfo de Maine* (Canadá/Estados Unidos), CIJ, Fallo, 12/10/1984.

46 *Ibid.*, Opinión Disidente del juez Gros, párrs. 41-44.

47 Francioni, Francesco, "Equity in International Law" (2009), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>.

48 *Plataforma Continental* (Jamaheiriya Árabe Libia/Malta), CIJ, Fallo, 03/06/1985, párrs. 45-47.

método para mitigar ciertas inequidades, no para modificar situaciones en detrimento de lo legal⁴⁹.

En el ámbito de los tribunales arbitrales, podemos mencionar el asunto sobre la *Fundición Trail*, en el cual el tribunal arbitral precisó que en las circunstancias del caso no existían normas de derecho internacional positivo aplicables a las situaciones planteadas por contaminación ambiental y que las normas que podían aplicarse, por analogía, eran las que regulaban la contaminación de los cursos de aguas. Para ello tuvo en cuenta las decisiones judiciales emanadas de la Corte Suprema de los Estados Unidos y del Tribunal Federal Suizo que resolvían las controversias planteadas entre los Estados federales y los cantones, relativas a la contaminación de las aguas⁵⁰. Asimismo manifestó que, teniendo en cuenta los principios del derecho internacional, como lo establecido en la ley americana, ningún Estado tenía derecho de hacer uso o permitir el uso de su territorio para realizar actividades que por las emanaciones de humo provocaran consecuencias graves al territorio o bienes de un Estado vecino y pudieran causar daño. Los árbitros en este caso —considerado el punto de partida de la protección jurisdiccional del derecho ambiental— resolvieron en función de la equidad *praeter legem*.

En relación con la equidad *contra legem*, la doctrina y la jurisprudencia es mayoritaria en reconocer que el poder que tiene el juez para descartar el derecho positivo requiere el acuerdo previo de las partes. Los jueces pueden guiarse por consideraciones de equidad en el derecho positivo, pero no pueden tomar una decisión basada en consideraciones extrañas al derecho. Algunos autores sostienen que, desde un punto de vista formal, la respuesta a esta cuestión se contempla en el artículo 38(2) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que analizaremos más adelante, donde de manera explícita se establece el consentimiento de las partes para que en una disputa el juez decida apartándose del derecho.

Respecto de esta función de la equidad, podemos citar la opinión individual del juez Ammoun en el caso *Barcelona Traction*, que expresa que la concepción de equidad que concibe la posible derogación del derecho no ha tenido nunca aplicación en derecho internacional y el juez internacional que se arrogara esa competencia se erigiría en legislador⁵¹.

En la sentencia arbitral conocida como *Rann of Kutch*⁵², que resolvió una disputa fronteriza entre India y Pakistán, se evaluó la equidad como un elemento extralegal asimilable a las cuestiones sociales, económicas o políticas, pero no como fuente formal del derecho.

Sin embargo, existen también opiniones doctrinarias que consideran que el derecho está en constante evolución y que lo que es *contra legem* en un momento puede, en una etapa posterior, ser concordante con la norma. La equidad puede, a través de esta función, anticipar la cristalización del derecho y proveer la justificación ética de su transformación. Como ejemplo de esta argumentación se menciona un supuesto de colapso de la economía de un país que lo lleva a la violación de las obligaciones contractuales hacia los inversionistas extranjeros. En el supuesto de que, a consecuencia de dicha situación económica, un juez fije una indemnización menor al valor en plaza de los bienes expropiados y se aparte del contenido del derecho, cabe preguntarse si, al hacerlo, no estaría aplicando la función *contra legem* de la equidad⁵³. Otro ejemplo puede darse en el ámbito de la protección de los derechos humanos, donde los pronun-

49 *Plataforma Continental* (Túnez/Jamahiríya Árabe Libia), doc. cit., párrafo. 66-71.

50 *Fundición de Trail* (Estados Unidos/Canadá), Laudo Arbitral, 10/04/1938 y 11/03/1941, R.I.A.A., vol. III, p. 1905. En este caso, el humo que provenía de una usina de fundición de plomo, situada en Canadá, fue dirigido a través de la acción ética hacia los Estados Unidos y provocó daños en las tierras de agricultores norteamericanos, que se tornaron improductivos. Canadá fue considerada responsable de los daños causados, aun cuando la propagación por razones climáticas estaba fuera de su control.

51 *Barcelona Traction*, doc. cit., p. 893.

52 *La frontera occidental indo-pakistani (Rann of Kutch)* (India/Pakistán), Laudo Arbitral, 19/02/1968, R.I.A.A., vol. XVII, p. 871.

53 Francioni, Francesco, "Compensation for Nationalisation of Foreign Property: The Borderland between Law and Equity", *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 24, n.º 2 (1975), pp. 255-283.

ciamientos de los tribunales europeo y americano han aplicado el principio *pro homine* con un claro sentido *contra legem*⁵⁴.

Si bien pueden tenerse en cuenta estas interpretaciones, mantenemos la opinión generalizada de que la equidad no puede estar contra el derecho.

2.3. La equidad como principio general de derecho

El artículo 38(1)(c) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece como fuente del derecho internacional "los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas". La equidad se transforma en fuente de derecho cuando es formalmente invocada como un principio general. Tal como manifiesta Charles de Visscher, los principios generales de derecho plantean un doble proceso, de abstracción primero y luego de generalización, que se manifiesta despojando a las reglas de derecho interno de sus particularidades y permite por un efecto de síntesis poner en relieve sus elementos más generales y de carácter universal⁵⁵.

Se pueden categorizar los principios de derecho como las reglas fundamentales del derecho internacional que no tienen un valor ni convencional ni consuetudinario, "los usos establecidos entre las naciones civilizadas, las leyes de humanidad y las exigencias de la conciencia pública", tal como lo expresa el Convenio IV de la Haya relativo a la leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907; como el conjunto de los principios comunes a los grandes sistemas de derecho contemporáneo aplicables al orden internacional; o como los principios jurídicos o políticos que se aplican a las relaciones políticas contemporáneas, tales como los referentes a las relaciones de amistad entre los Estados, la soberanía y la protección de los recursos naturales⁵⁶. La equidad encuentra acogida en estos principios comunes.

En el ámbito jurisdiccional, se ha invocado la equidad como principio general de derecho en el caso, resuelto por la CPJI, de las *Tomas de agua del río Mosa*⁵⁷. El juez Hudson, en su opinión individual, expresó que las reglas conocidas como principios de equidad han sido consideradas luego de un largo tiempo como parte del derecho internacional y, con ese carácter, han sido aplicadas por los tribunales internacionales. El artículo 38 del Estatuto de la CIJ prescribe expresamente la aplicación de los "principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas" y más de una nación, en su sistema jurídico, contempla los principios de equidad. La Corte no ha sido expresamente autorizada por su Estatuto a aplicar los principios de equidad en forma independiente de los principios de derecho. Es un principio general que la reparación es el corolario de la violación de obligaciones jurídicas y que toda violación de un acuerdo genera la obligación de reparar. En este caso, un tribunal de derecho internacional no puede ignorar

54 Quienes sostienen esta posición afirman que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció *contra legem* cuando estableció la carencia de efectos jurídicos de las leyes internas y la anulación de ciertas disposiciones de derecho interno en el caso *Barrios Alto c. Perú*, Corte IDH, Sentencia de fondo, 14/03/2001, párrafo. 4 y 51; cuando consagró el "derecho a la verdad" como un nuevo derecho humano en el caso *Kawas Fernández c. Honduras*, Corte IDH, Sentencia de fondo, reparaciones y costas, 03/04/2006, párrafo. 188-189; o cuando dispuso la suspensión de los efectos del proceso judicial y de la sanción establecida en el orden interno en el caso *Kimel c. Argentina*, Corte IDH, Sentencia de fondo, reparaciones y costas, 02/08/2008, párrafo. 121. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que, para que una restricción sea aceptada, debe implicar la existencia de una necesidad imperiosa —y no solo deseable— y, si no se contempla esta situación en las normas del derecho interno, se impone su anulación, en el caso *Dudgeon c. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte*, TEDH, Fallo, 22/10/1981, párrafo. 51. Ver Drmas de Clément, Zlata, "La equidad *contra legem* en la sentencia del 30 de noviembre de 2012 de la CIJ en el asunto Ahmadou Badji Diallo", en *Estudios de Derecho Internacional en Homenaje al Profesor Hugo Llanos Manilla*, Picard, E. y Llanos Mardones, H. (eds.), Abeledo Perrot-Thomson Reuters, Santiago, tomo I, 2012, pp. 39-48.

55 De Visscher, Charles, *Théories et réalités en droit international public*, Pédone, París, 4.ª edic., 1970, p. 419. Ver también Barberis, Julio A., *Formación del derecho internacional*, Abaco, Buenos Aires, 1994, pp. 223-227. Del mismo autor, *Fuentes del derecho internacional*, Editora Platense, Buenos Aires, 1973, p. 174.

56 Por ejemplo, el principio de equidad intergeneracional en el ámbito del derecho ambiental, entendido como la necesidad de que las generaciones futuras tengan las mismas condiciones medioambientales que las que gozan las actuales, o el principio de compartir de manera equitativa los beneficios. Podemos destacar que, en el derecho internacional, se fue desarrollando, en aquellos ámbitos donde no existían acuerdos convencionales, una utilización de los principios generales de derecho que responden a valoraciones jurídicas universalmente compartidas.

57 *Tomas de Aguas del Mosa* (Bélgica o. Holanda), CPJI, Fallo, 29/08/1937, CPJI Serie A/B, n.º 70, pp. 78-78.

las circunstancias particulares que pueden ser contempladas por el principio de equidad. Este mismo principio general que establece la equidad en la reparación fue contemplado en la sentencia de la CPJI, adoptada unos años antes, en el caso de la *Fábrica de Chorzow*⁵⁸.

En la cuestión relativa a la *Plataforma Continental del Mar del Norte*, la CIJ precisó que debe entenderse por principios de equidad⁵⁹. Estos constituyen, sobre la base de preceptos generales de justicia y de buena fe, verdaderas reglas de derecho en materia de delimitación. En otras palabras, dijo la CIJ, no se trata de aplicar la equidad simplemente como una representación de la justicia abstracta, no constituye una suerte de derecho natural, sino de aplicar una regla de derecho que recurre a principios de equidad conforme las ideas que siempre han inspirado el desarrollo del régimen jurídico de la plataforma continental.

En el caso de la *Plataforma continental Libia/Túnez*, se expresó que la Corte, cuyo fin es aplicar justicia, no puede dejar de cumplir esa labor⁶⁰. Y en muchos casos la equidad se opone a rígidas normas del derecho positivo para que ese rigor sea atemperado y con el fin de que, de esta manera, la justicia sea aplicada. La noción jurídica de equidad es un principio general directamente aplicado en tanto constituye derecho.

2.4. La equidad como proceso *ex aequo et bono*

Es en el marco del concepto *ex aequo et bono* que la equidad se puede apartar del derecho y se constituye en fundamento independiente de la decisión. Así se contempla en el artículo 38(2) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia: "La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio *ex aequo et bono*, si las partes así lo convinieren".

En este supuesto se abre una vía de solución diferente de las que hemos analizado hasta ahora, ya que, por un lado, se hace abstracción del derecho aplicable a los intereses contrapuestos y, por el otro, es condición *sine qua non* que sean las partes las que requieran al tribunal este medio para resolver la controversia.

Esta potestad nunca fue confiada a los jueces de la CPJI ni a los de la CIJ, por lo tanto, no ha habido casos resueltos a la luz del artículo 38(2); si en cambio en varias sentencias arbitrales se invoca el proceso *ex aequo et bono* y en algunas de ellas se ha decidido de esa manera creando una nueva relación jurídica entre las partes.

En la cuestión sobre el *Límite fronterizo entre Brasil y la Guyana Francesa*, Francia planteó que, si existía voluntad de investir al gobierno de la Confederación Suiza de arbitrar *ex aequo et bono*, era para dar al árbitro una muestra de la confianza en la justicia y en su imparcialidad⁶¹. El objeto era otorgarle todos los medios necesarios para ejercer libremente su misión y poder decidir, sin restricción, ya sea en el terreno del derecho o de la equidad.

En los procedimientos arbitrales de los casos *Compañía del Orinoco*⁶², *Armadores noruegos*⁶³ y *Buque I'm Alone*⁶⁴ se recurrió al proceso *ex aequo et bono* para ser aplicado en especial en las compensaciones económicas.

Un interesante caso se planteó en 1938, luego de finalizada la guerra del Chaco en el ámbito latinoamericano. Bolivia y Paraguay, los Estados enfrentados en este conflicto, firmaron un reglamento por el cual acordaron que el límite entre los dos países iba a ser fijado por los Estados Unidos, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay a través del procedimiento *ex aequo et bono*. La sentencia arbitral dictada no plasmó ninguna consideración jurídica (solo fijó una línea de demarcación), y fue aceptada por las partes⁶⁵.

En el caso *Rann de Kutch*, el tribunal expresó que, como las dos partes lo habían manifestado, la equidad forma parte del derecho internacional, por ello las partes, a discreción, pueden presentar y desarrollar su punto de vista basándose en los principios de equidad⁶⁶. Un tribunal internacional no tiene el poder de decidir una cuestión *ex aequo et bono* fuera de las fronteras del ámbito del derecho si las partes no le han conferido por acuerdo ese poder. El tribunal consideró que el acuerdo del 30 de junio de 1965 (que sometía la controversia al tribunal, de común acuerdo entre las partes) no establecía de manera clara y fuera de toda duda su facultad de decidir *ex aequo et bono*. Por lo tanto, el tribunal, como las partes por un acuerdo posterior no le habían conferido el poder de decidir *ex aequo et bono*, decidió que no poseía esa competencia.

2.5. La aplicación de la equidad en los distintos institutos del derecho internacional

Los principios de equidad y de solución equitativa no solo se desarrollan en el ámbito jurisdiccional, sino en gran parte del sistema jurídico del derecho internacional, tal como el derecho del mar, la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable, los derechos humanos y las relaciones económicas internacionales⁶⁷.

En el ámbito del derecho del mar, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982) consagra la solución equitativa de los conflictos que se puedan plantear en la delimitación de los espacios marítimos sometidos a las jurisdicciones de los Estados, como también la utilización equitativa y eficiente de los recursos marinos. En este sentido, la regla generalmente aceptada entre los Estados con costas adyacentes o enfrentadas para la delimitación del mar territorial es la línea media o equidistante (art. 15), y para la delimitación de la zona económica exclusiva (art. 74) y de la plataforma continental (art. 83, inc. 1) de los Estados en iguales condiciones geográficas se deberá recurrir al acuerdo para arribar a una solución equitativa. Con relación a la explotación de los recursos vivos en la zona económica exclusiva, la mencionada Convención establece que los Estados sin litoral tendrán derecho a participar en la explotación de los recursos vivos de las zonas económicas exclusivas de los Estados ribereños; sobre una base equitativa (art. 69, inc. 1) y siguiendo este criterio, establece que los beneficios financieros y económicos derivados de las actividades en los fondos marinos y oceánicos se distribuirán de manera equitativa (arts. 140; 155, inc. 2; 160, inc. 2; 173, inc. 2).

Podemos mencionar también los tratados de protección de determinados recursos vivos de alta mar, en los cuales se regula su utilización equitativa y sustentable⁶⁸.

En las relaciones económicas internacionales, la equidad ha jugado un papel importante en la construcción de herramientas que permitan disminuir las diferencias entre los países más desarrollados y los menos desarrollados a través de los principios equitativos de redistribución, o como base para determinar adecuadas y efectivas compensaciones frente a daños. La equidad tiene un rol esencial en lograr disminuir la injusticia social provocada por la desigualdad extrema de ingresos, riquezas o en la distribución de alimentos y otros factores⁶⁹.

En el contexto del derecho ambiental y el desarrollo sustentable, la aplicación del principio de utilización equitativa de los recursos y protección medioambiental ha permitido el es-

58 *Fábrica de Chorzow* (Alemania c. Polonia), Fallo, 13/09/1928, CPJI Serie A, n.º 17, p. 48.

59 *Plataforma Continental del Mar del Norte*, doc. cit., parág. 85.

60 *Plataforma Continental* (Túnez/Jamahiriyá Árabe Libia), doc. cit., parág. 71.

61 *Sentencia Arbitral relativa a la cuestión de las fronteras entre Brasil y la Guyana Francesa*, Decisión, 01/12/1990, R.I.A.A., vol. xxviii, p. 357.

62 *The Orinoco Steamship Company* (Estados Unidos c. Venezuela), Laudo Arbitral, 25/10/1910, R.I.A.A., vol. xi, pp. 227-241.

63 *Reclamos de armadores noruegos*, doc. cit., pp. 307-348.

64 *S.S. "I'm Alone"* (Canadá/Estados Unidos), Laudo Arbitral, 30/06/1933 y 05/01/1935, R.I.A.A., vol. iii, pp. 1609-1618.

65 *Asunto del Chaco* (Bolivia/Paraguay), Laudo Arbitral, 10/10/1938, R.I.A.A., vol. iii, pp. 1822-1825.

66 *La frontera occidental Indo-pakistani (Rann of Kutch)*, doc. cit., p. 11.

67 Francioni, Francesco, op. cit., p. 19.

68 Por ejemplo, el Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos en el Alta Mar del Pacífico Sudeste; el Acuerdo de Galápagos (2002) firmado por Chile, Colombia, Ecuador y Perú; el Convenio sobre la Pesca y Conservación de los Recursos Vivos en el mar Báltico y los Belts (1972) firmado por los Estados ribereños del Mar Báltico y la Comunidad Europea.

69 La Comisión de Derechos Humanos, en su Resolución 2002/69, invitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que, en consulta con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y todas las organizaciones e instituciones internacionales pertinentes, presentara un informe sobre la importancia y la aplicación del principio de la equidad como cuestión prioritaria, tanto a nivel nacional como internacional.

tablecimiento de estándares técnicos de protección y se ha incorporado a numerosos acuerdos convencionales y declaraciones⁷⁰.

En el ámbito de los derechos humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), en el artículo 11(2)(b), que trata del derecho a estar protegido contra el hambre, se dispone que los Estados parte adopten, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas necesarias para, entre otras cosas, asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades. En el preámbulo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) se reconoce que el establecimiento del nuevo orden económico internacional basado en la equidad y la justicia contribuirá de manera significativa a la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer. En la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990) se menciona expresamente la promoción de condiciones óptimas, equitativas, humanas y legales en relación con la migración internacional de los trabajadores y sus familiares.

En el preámbulo del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2002) se reconoce que la erradicación de la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía será más fácil si se adopta un enfoque global que permita hacer frente a todos los factores que contribuyen a ello, como, entre otros, las estructuras socioeconómicas no equitativas.

Por último, en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, en particular, se reconoce la responsabilidad colectiva de mantener los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad a escala mundial, a la vez que la responsabilidad correspondiente a cada sociedad en particular⁷¹.

Podemos concluir que la equidad tiene como marco el derecho existente y su función es adaptar la regla jurídica a las circunstancias particulares de un caso cuando se requiere completar la aplicación del derecho o atemperar su aplicación, pero no se la concibe como un proceso de formación de normas jurídicas por sí misma.

70 Comisión de Derechos Humanos, *El derecho al desarrollo. La importancia y la aplicación del principio de la equidad tanto a nivel nacional como internacional*, Doc. E/CN.4/2008/25 (disponible en <http://www.un.org>).

Con relación a los tratados, podemos mencionar el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), que en su artículo 1 dispone la conservación de la diversidad biológica, su utilización sostenible y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de esa utilización; y la Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación (1997), que en su artículo 3 establece la utilización de un curso de agua internacional de manera equitativa y razonable.

71 Resolución A/RES/55/2, Declaración del Milenio, 13/09/2000 (disponible en <http://www.un.org/spanish/millennio/ares552.pdf>).

CAPÍTULO 11

ACTOS UNILATERALES DEL ESTADO (PRIMERA PARTE)

Veronica Lavista y Gisela Makowski

1. Definición y principios rectores

La conducta de un Estado puede generar obligaciones internacionales más allá de la conclusión de tratados. Así, como se trató en el capítulo 5, los actos unilaterales de los Estados tienen relevancia en particular respecto de la formación de la costumbre¹. Sin embargo, lo que se analizará en este capítulo es bajo qué circunstancias los actos unilaterales de un Estado pueden obligar a dicho sujeto fuera del contexto de la celebración de un tratado o la formación de una norma consuetudinaria.

Existen dos posturas respecto de la definición de actos unilaterales: una sostiene que "el concepto de acto jurídico necesariamente implica una manifestación expresa de la intención de ser obligado por parte del Estado autor" y otra que "cualquier comportamiento unilateral por el Estado que produce efectos en el plano internacional puede caracterizarse como un acto internacional"². Sintetizando ambas corrientes, se han definido los actos unilaterales como "una expresión de voluntad que emana de un Estado o Estados que produce efectos legales de conformidad con el derecho internacional"³.

En 2006 la Comisión de Derecho Internacional, a la que se le había encomendado el estudio de los actos jurídicos unilaterales⁴, produjo una serie de "Principios rectores aplicables a las declaraciones unilaterales de los Estados capaces de crear obligaciones jurídicas"⁵ (en adelante, Principios rectores). En ese mismo año, la Asamblea General "tomó nota" de tales principios y recomendó su difusión⁶. Ahí la Comisión definió un acto unilateral *stricto sensu*, "es decir, los que adoptan la forma de declaraciones formales formuladas por un Estado con

1 Crawford, James, *Brownlie's Principles of Public International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 418.

2 Rodríguez Cedeño, Víctor y Torres Cazorla, María Isabel, "Unilateral Acts of States in International Law" (2013), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>, párr. 1.

3 Ibid.

4 En 1998, la Asamblea General, por Resolución 51/180, invitó a la CDI a examinar la cuestión de los actos unilaterales de los Estados y establecer su alcance.

5 El relator especial destacó que estos principios no se refieren a actos unilaterales que "se realicen en el marco y sobre la base de una autorización expresa del derecho internacional", como "las leyes que fijan la extensión del mar territorial o las reservas a los tratados, que son actos unilaterales, estrechamente delimitados por determinadas normas de derecho internacional", Actos unilaterales de los Estados, Informe del Grupo de Trabajo, UN Doc. A/CN.4/703, p. 2.

6 Resolución aprobada por la Asamblea General el 04/12/2006 sobre el Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 58.º período de sesiones, UN Doc. A/Res/61/34, p. 2.

la intención de producir obligaciones en virtud del derecho internacional⁷ en los siguientes términos:

Unas declaraciones formuladas públicamente por las que se manifieste la voluntad de obligarse podrán surtir el efecto de crear obligaciones jurídicas. Cuando se dan las condiciones para que eso ocurra, el carácter obligatorio de tales declaraciones se funda en la buena fe; en tal caso, los Estados interesados podrán tenerlas en cuenta y basarse en ellas; esos Estados tienen derecho a exigir que se respeten esas obligaciones⁸.

Esta definición ha sido criticada al sostener que asume, sin sustento, que los actos unilaterales son promesas⁹ y que lo correcto es analizar qué declaraciones o representaciones del Estado comprometen su obligación de actuar de buena fe; este análisis solo puede decidirse de acuerdo con las circunstancias, ya que "nunca ha sido el caso que todas [las declaraciones] lo hicieron, [y esto] menos aún puede ser cierto en la era de las frecuentes conferencias de prensa e internet"¹⁰. Esta crítica se basa en que los actos unilaterales no deben entenderse como "cualquier acto de un Estado sino en un sentido más acotado (a determinarse) de 'actos implicando la buena fe del Estado' o, más simplemente, 'compromisos y representaciones que impliquen un compromiso'"¹¹.

Uno de los principios rectores de la obligatoriedad de los actos unilaterales es el principio de la buena fe, según surge de la decisión de la Corte Internacional de Justicia en los casos de los *Ensayos Nucleares*. Así se ha dicho que "un Estado puede asumir obligaciones jurídicas por medio de una declaración unilateral, cuando su intención ha sido obligarse de acuerdo con sus términos. La Corte basa esta norma en el principio de la buena fe"¹². La importancia de este principio será reflejada, por ejemplo, en la sección sobre revocación o modificación de actos unilaterales.

El carácter vinculante de un acto unilateral puede surgir, también, de una disposición de un tratado o de una regla de la costumbre internacional¹³. Asimismo, "una declaración, aunque no dé lugar directamente a derechos legales y obligaciones para terceros Estados, puede de todas formas ser legalmente significativa para ellos de otras formas, por ejemplo como evidencia de una conducta o dando lugar a un estoppel o renuncia de derechos"¹⁴.

2. ¿Son fuente de derecho internacional? Tipos de actos unilaterales

Existen múltiples formas de actos unilaterales, tales como: declaraciones, notificaciones, protestas, renunciaciones, reconocimientos, otorgamientos de nacionalidad, ciertos actos vinculados a la conclusión de tratados, incluyendo firma, adhesión, aprobación y ratificación¹⁵. Cabe preguntarse si todos estos actos unilaterales son fuente de derecho internacional, es decir, si son creadores de normas jurídicas internacionales.

Pero para tratar esta cuestión es necesario, en primer lugar, distinguir entre dos tipos de actos unilaterales: por un lado, aquellos que están destinados a producir efectos jurídicos con relación a uno u otros actos unilaterales o multilaterales —como, por ejemplo, una protesta para impedir la formación de una costumbre, o la manifestación del consentimiento en obligarse en el proceso de celebración de un tratado— que no son actos unilaterales autónomos o independientes, sino que sus consecuencias jurídicas se producen en el contexto de otros

actos¹⁶, y por el otro, los actos unilaterales autónomos, es decir, aquellos que constituyen una manifestación de voluntad de uno o varios sujetos de derecho internacional con capacidad suficiente, no vinculada con ningún acto convencional, tendiente a establecer una regla de derecho en el orden jurídico internacional¹⁷. Es únicamente a estos últimos a los que nos referiremos en este capítulo.

Las opiniones respecto de si estos actos son fuente de derecho están divididas. Como se verá, parte de la doctrina ha sostenido que los actos unilaterales autónomos no constituyen una fuente de derecho, aun en el caso de los emanados de un solo Estado.

Así, por ejemplo, se ha afirmado que los actos unilaterales pueden contribuir o influenciar en el funcionamiento de las demás fuentes de derecho, y muchas veces terminan siendo el origen de normas consuetudinarias. Ahora bien, ello no significa que el Estado sea creador de normas de derecho internacional a través de actos unilaterales. Ciertos actos pueden dar nacimiento a ciertos derechos, pero ello no constituye fuente de derecho internacional¹⁸.

Barberis, por ejemplo, entiende que "sólo los actos unilaterales que reúnen determinadas características son creadores de normas jurídicas internacionales"¹⁹. Eduardo Jiménez de Aréchaga, en el mismo sentido, sostiene que, del análisis de la jurisprudencia y la práctica internacional, "los actos unilaterales pueden constituir una fuente formal autónoma del Derecho Internacional"²⁰.

Sin embargo, otros afirman que la doctrina internacional, en general, no otorga a los actos unilaterales calidad de fuente autónoma en cuanto proceso de creación de derecho, lo que no implica desconocerle efectos jurídicos (en razón de aplicar una norma positiva como la obligación de actuar de buena fe, que constituye un principio general de derecho)²¹.

Como vemos, si bien la doctrina no es pacífica con relación a si se trata de una fuente autónoma de derecho internacional, nadie les niega a los actos jurídicos unilaterales —que reúnen determinadas características— la calidad de generar obligaciones para el Estado que realiza el acto.

En este sentido, la CIJ afirmó en los asuntos sobre los *Ensayos nucleares*²² que Francia había asumido una obligación de comportamiento que producía efectos jurídicos para toda la comunidad internacional, sin que fuese necesaria ninguna aceptación o reacción ulterior de otros Estados. La Corte le asignó a la declaración de Francia efectos vinculantes, creando una obligación jurídica individual, lo cual descansa, según la CIJ, en el principio de buena fe²³.

A continuación definiremos algunos actos unilaterales autónomos, pues otros serán tratados en otras secciones de esta obra.

2.1. Promesa

Es una declaración unilateral por la que un Estado se compromete a realizar algún acto o a adoptar determinada actitud respecto de otro/s Estado/s sin sujetar tal acto o comportamiento a una contraprestación del receptor²⁴. Pueden citarse como ejemplo las declaraciones públicas de autoridades francesas en los casos de los *Ensayos nucleares*, que anunciaron la

7 Principios rectores aplicables a las declaraciones unilaterales de los Estados capaces de crear obligaciones jurídicas, UN Doc. A/CN.4/703, p. 8.

8 Ibid., Principio 1.

9 Crawford, James, *op. cit.*, p. 416.

10 Ibid.

11 Ibid.

12 Podestá Costa, Luis A. y Ruda, José M., *Derecho Internacional Público*, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1979, t. 1, p. 22 (citas omitidas).

13 Jennings, Robert y Watts, Arthur (eds.), *Oppenheim's International Law*, Oxford University Press, Oxford, 1996, vol. 1, p. 1190.

14 Ibid., p. 1192 (citas omitidas).

15 Ibid., p. 1188.

16 Pastor Ridruejo, José, *Curso de Derecho Internacional Público*, Tecnos, Madrid, 5.ª edic., 1994, p. 165.

17 Barberis, Julio A., *Formación del Derecho Internacional*, Abaco, Buenos Aires, pp. 130-140.

18 Barberis da como ejemplo la adquisición de la mayoría de edad, hecho que trae aparejados determinados derechos y obligaciones. Sin embargo, el hecho no es fuente de derecho; la mayoría de edad no crea el derecho, sino que sus consecuencias están contempladas en una norma jurídica. Se trata de la aplicación de una norma general a un caso particular. Ver, Barberis, Julio, *op. cit.*, p. 128.

19 Barberis, Julio, "Los actos jurídicos unilaterales como fuente de derecho internacional público", en *Hacia un Nuevo Orden Internacional y Europeo*, Tecnos, Madrid, 1993, p. 106.

20 Jiménez de Aréchaga, Eduardo, *Derecho Internacional Público*, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, t. 1, 1996, p. 285.

21 Moncayo, Guillermo; Vinuesa, Raúl y Gutiérrez Posse, Hortensia, *Derecho Internacional Público*, Zavallá, Buenos Aires, t. 1, 2.ª reimpr., 1987, p. 162.

22 *Ensayos Nucleares* (Nueva Zelanda c. Francia), CIJ, Fallo, 20/12/1974, parág. 52.

23 Moncayo, Guillermo; Vinuesa, Raúl y Gutiérrez Posse, Hortensia, *op. cit.*, p. 162.

24 Rodríguez Carrión, Alejandro, *Lecciones de Derecho Internacional Público*, Tecnos, Madrid, 6.ª edic., 2006, p. 152.

intención de Francia de cesar la realización de los ensayos nucleares atmosféricos luego de concluir la serie de ensayos de 1974²⁵.

2.2. Protesta

Una protesta es un acto realizado por un Estado en el que objeta un acto realizado o contemplado por otro Estado²⁶. Por ejemplo, como se verá en el capítulo 22 de esta obra, la República Argentina ha efectuado numerosas protestas en relación con los actos realizados por el Reino Unido en las Islas Malvinas. La protesta tiene importancia respecto de la aquiescencia, según se verá en el capítulo siguiente y también es relevante en relación con el establecimiento de una costumbre que sea obligatoria para ese Estado, según se ha visto en el capítulo 5 de esta obra. Así, un Estado no será considerado obligado por una costumbre internacional si se determina que ha realizado actos que indican que es un objeter persistente.

2.3. Reconocimiento

El reconocimiento es "una manifestación de voluntad de un Estado por la que considera legítima una situación o pretensión"²⁷. Es especialmente relevante el caso del reconocimiento de Estados y de gobiernos, que será tratado en mayor detalle en el capítulo 18 de esta obra. También es cada vez más frecuente en materia de responsabilidad internacional, cuando un Estado reconoce haber cometido un ilícito internacional, desprendiéndose de ello una serie de consecuencias jurídicas²⁸.

2.4. Notificación

La notificación es un acto a través del cual un Estado informa algún hecho o pretensión que puede tener consecuencias jurídicas para aquel que es informado²⁹. Si bien se utiliza frecuentemente en el ámbito del derecho de los tratados, también puede usarse en otro contexto, por ejemplo, cuando un Estado notifica a otro la existencia de una controversia o conflicto internacional.

2.5. Renuncia

La renuncia es un acto unilateral por el que el Estado abandona voluntariamente un derecho o el ejercicio de un derecho³⁰. En el caso de *Ciertos empréstitos noruegos*, la CIJ se refirió a la cuestión del "abandono" por parte de Noruega de una pretensión vinculada a una objeción jurisdiccional planteada ante la Corte, y puntualmente sostuvo que el abandono no puede ser presumido o inferido, sino que debe declararse de manera expresa³¹.

2.6. Otros

La aquiescencia (inacción calificada desde el punto de vista jurídico, de la que se derivan efectos en el plano del derecho internacional)³² y el *estoppel* (pérdida de derechos para un

25 *Ensayos Nucleares* (Australia c. Francia), doc. cit., parág. 41; *ibid.* (Nueva Zelandia c. Francia), parág. 44.

26 *Oppenheim's International Law*, op. cit., p. 1189.

27 Rodríguez Carrión, Alejandro, op. cit., p. 152.

28 El reconocimiento de responsabilidad internacional cada vez es más frecuente en el contexto de los procesos por violación de derechos humanos que tramitan ante órganos de protección como, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto, ver *Peñal Miguel Castro Castro c. Perú*, Corte IDH, Sentencia de fondo, reparaciones y costas, 26/11/2006, parág. 448 y ss.; *Vargas Areco c. Paraguay*, Corte IDH, Sentencia de fondo, reparaciones y costas, 26/09/2006, parág. 152; *Goiburú y otros c. Paraguay*, Corte IDH, Sentencia de fondo, reparaciones y costas, 22/09/2006, parág. 173 y *Servellón García y otros c. Honduras*, Corte IDH, Sentencia de Fondo, reparaciones y costas, 21/09/2006, parág. 198, entre muchos otros.

29 Rodríguez Carrión, Alejandro, op. cit., p. 152.

30 *Ibid.*

31 *Ciertos empréstitos noruegos* (Francia c. Noruega), CIJ, Fallo, 06/07/1957, *ICJ Reports* 1957, p. 28.

32 Pastor Ridruejo, José, op. cit., p. 172.

Estado que, debido a su actitud pasiva —aquiescencia— ha creado una determinada situación jurídica, la cual llevó a otro Estado a actuar en consecuencia)³³ se analizarán en el capítulo siguiente de esta obra.

3. Elementos reconocidos por la jurisprudencia internacional para generar obligatoriedad

En su trabajo sobre actos unilaterales, la CDI se refiere a una serie de principios rectores de la materia que se desarrollarán a continuación. Estos incluyen: la capacidad que tienen todos los Estados para contraer obligaciones unilaterales a través de declaraciones unilaterales; los efectos jurídicos de tales declaraciones, que dependerán de su contenido, circunstancias y reacciones; la competencia de personas para obligar al Estado; la forma en que pueden realizarse; a quiénes pueden ser dirigidas; la manera en que deben interpretarse aquellas declaraciones que no sean claras y específicas; su nulidad si son contrarias a una norma imperativa de derecho internacional; el hecho de que no generan obligaciones para terceros Estados, y, por último, que no pueden ser revocadas arbitrariamente³⁴.

3.1. Capacidad de la persona en obligar al Estado

Todos los Estados tienen capacidad para obligarse a través de una declaración unilateral. La cuestión, entonces, es determinar quiénes podrán realizar tal declaración y obligar al Estado.

Se ha asemejado la capacidad de una persona para obligar al Estado a través de una declaración unilateral con la necesaria para la conclusión de un tratado. La CDI se refiere a los jefes de Estado, de gobierno y ministros de relaciones exteriores, así como a aquellos otros que estén autorizados a obligar al Estado en la materia de su competencia³⁵. El reconocimiento de este principio como costumbre internacional fue aceptado por la Corte Internacional de Justicia en el caso de las *Actividades Armadas* (Congo c. Bélgica)³⁶. Así, se presume que un ministro extranjero tiene capacidad para obligar al Estado³⁷.

3.2. Intención de obligar al Estado

La importancia de la voluntad de obligarse por parte del Estado que realiza la declaración unilateral es manifiesta. Así, tanto la Corte Internacional de Justicia en los casos de los *Ensayos Nucleares* como la CDI en sus Principios rectores lo destacan como un elemento esencial para determinar el carácter vinculante de un acto unilateral: "[...] un compromiso de este tipo, si fue otorgado públicamente, y con la intención de obligarse, aun cuando no fue realizado en el contexto de negociaciones internacionales, es vinculante"³⁸ y "Unas declaraciones formuladas públicamente por las que se manifieste la voluntad de obligarse podrán surtir el efecto de crear obligaciones jurídicas"³⁹, respectivamente.

La relevancia de manifestar la intención en obligarse por parte de un Estado es un corrolario necesario de la aplicación del principio de la buena fe como rector en esta materia.

3.3. Forma de realizar un acto unilateral

Existe un principio de libertad de formas para la realización de un acto unilateral. Así, una declaración unilateral puede ser realizada en forma oral o escrita⁴⁰.

33 *Ibid.*, p. 170.

34 Principios rectores, doc. cit., Principios 2-10.

35 *Ibid.*, Principio 4.

36 Rodríguez Cedeño, Víctor y Torres Cazorla, María Isabel, op. cit., párrs. 15-18.

37 Crawford, James, op. cit., p. 415 (citas omitidas).

38 *Ensayos Nucleares* (Nueva Zelandia c. Francia), doc. cit., parág. 48 (énfasis agregado).

39 Principios rectores, doc. cit., Principio 1 (énfasis agregado).

40 *Ibid.*, Principio 5.

3.3.1. Publicidad

La práctica internacional indica que, para que un acto unilateral sea considerado vinculante, debe tener publicidad⁴¹. En los casos de los *Ensayos Nucleares*, la Corte destacó la importancia del elemento público de la declaración unilateral. Al respecto sostuvo: "[...] un compromiso de este tipo, si fue otorgado públicamente, y con la intención de obligarse, aun cuando no fue realizado en el contexto de negociaciones internacionales, es vinculante"⁴².

3.3.2. Destinatarios

En sus Principios rectores aplicables a las declaraciones unilaterales de los Estados capaces de crear obligaciones jurídicas, la CDI señaló que tales declaraciones pueden estar dirigidas a "la comunidad internacional en su conjunto, a uno o varios Estados o a otras entidades"⁴³. En los casos de los *Ensayos Nucleares*, la Corte estableció que las declaraciones de Francia eran obligatorias aunque no fueron dirigidas a un Estado o Estados específicos, sino *erga omnes*, y a pesar de que no fueran aceptadas por otro Estado⁴⁴. Este principio luego fue aplicado también en los casos *Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* (Nicaragua c. EE.UU.) y *Disputa Fronteriza* (Burkina Faso/Mali)⁴⁵.

4. Declaraciones de funcionarios públicos

También se cuestionaron en el seno de la CDI las declaraciones que formulan los agentes de un Estado en un proceso legal, y la posibilidad de que sean considerados actos unilaterales. Según el relator especial que se ocupó de este tema, tales declaraciones pueden ser unilaterales en el sentido señalado si resultan autónomas; si mediante ellas se realiza una promesa o un reconocimiento. Su interpretación, que debe ser restrictiva, como lo dijo la CIJ en los casos de los *Ensayos Nucleares*, puede determinar si se trata o no de un acto puramente unilateral. En el caso *Groenlandia Oriental*, la CPJI reconoció que una declaración del ministro de Relaciones Exteriores de un Estado podía ser vinculante para ese Estado⁴⁶. Recientemente, en la providencia sobre medidas provisionales del caso de *Cuestiones relativas a la confiscación y detención de ciertos documentos y datos*, la CIJ sostuvo que "el Agente de Australia afirmó que 'el Procurador de Australia [tenía] la autoridad real y ostensible para obligar a Australia como cuestión tanto de derecho australiano como de derecho internacional'. La Corte no tiene razón para creer que el compromiso escrito de fecha 21 de enero de 2014 no será implementado por Australia. Una vez que un Estado se ha comprometido de esa forma en relación con su conducta, su buena fe en cumplir con tal compromiso debe presumirse"⁴⁷.

5. Efectos de un acto unilateral para terceros Estados u otros sujetos del derecho internacional

Tal como venimos analizando, en principio, un acto unilateral no puede ser oponible a terceros Estados. En la medida en que no existe una relación de subordinación entre los sujetos soberanos, es imposible imponer obligaciones sin su consentimiento. Sin embargo, pueden darse situaciones particulares, donde un acto unilateral de un Estado pueda crear ciertos deberes que conciernen a esos sujetos en virtud de normas convencionales o consuetudinarias.

41 Rodríguez Cedeño, Víctor y Torres Cazorla, María Isabel, *op. cit.*, párr. 19.

42 *Ensayos Nucleares* (Nueva Zelanda c. Francia), doc. cit., parág. 46.

43 Principios rectores, doc. cit., principio 6.

44 Aunque el Prof. Crawford sostiene que tal principio es específico a los hechos del caso, destacando la duda de la Corte al establecer que cualquiera de los demandantes podrían solicitar una revisión de la situación si Francia no cumplía con lo que la Corte había determinado que era un compromiso; Crawford, James, *op. cit.*, p. 417, n. 11.

45 *Ibid.*, p. 418 (citas omitidas).

46 *Estatuto jurídico de Groenlandia Oriental* (Noruega c. Dinamarca), CPJI, Fallo, 05/04/1933, *PCIJ Serie A/B*, n.º 53, p. 71.

47 *Cuestiones relativas a la confiscación y detención de ciertos documentos y datos* (Timor-Leste c. Australia), CIJ, Providencia sobre medidas provisionales, 03/03/2014, parág. 44 (traducción libre).

Además de su contenido para determinar sus efectos jurídicos, hay que tener en cuenta todas las circunstancias de hecho en que se produjeron y las reacciones que suscitaron. Es decir, las razones por las que el Estado decidió obligarse unilateralmente, comprometiéndose con otros Estados, sin recurrir a la vía de la negociación, y las reacciones del destinatario e incluso de terceros Estados.

En sus decisiones sobre los *Ensayos Nucleares*, la Corte Internacional de Justicia sostuvo que "Para apreciar las intenciones del autor de un acto unilateral (de la que puede nacer una obligación jurídica), hay que tener en cuenta todas las circunstancias de hecho en las cuales se realiza el acto"⁴⁸. Las declaraciones francesas no fueron destinadas solo a los demandantes, sino que tenían un carácter *erga omnes*. La negociación con todos los Estados era imposible y ello justificaba la formulación de declaraciones unilaterales, es decir, esas fueron las circunstancias por las que Francia se comprometió a suspender los ensayos nucleares.

En el caso de la *Disputa Fronteriza* (Burkina Faso/Mali), la Sala de la Corte Internacional de Justicia examinó también las circunstancias, aunque para llegar a una conclusión distinta, y expresó que, "si los Estados interesados pueden obligarse por la vía normal de un acuerdo formal, no habría que interpretar la declaración hecha por uno de ellos como un acto unilateral que conlleva efectos jurídicos [...]"⁴⁹. La Sala también concluyó, como vimos antes, que la declaración hecha por el jefe del Estado de Mali del 11 de abril de 1975 no podía ser considerada como un acto unilateral que produce efectos jurídicos en relación con esa controversia⁵⁰.

Los términos de la declaración deben ser claros y específicos, como lo consideró la CIJ en el caso de las *Actividades armadas sobre el territorio del Congo* (Congo c. Ruanda) en 2006⁵¹. El contexto y las circunstancias fueron destacados por la Corte en sus decisiones sobre los *Ensayos Nucleares*, antes citadas.

6. Revocación de actos unilaterales

Es claro que, en primera instancia, los actos unilaterales pueden ser revocados o modificados por el Estado. La posibilidad de que los actos unilaterales sean modificados por el Estado constituye un aspecto complejo debatido con profundidad en la CDI.

Los actos jurídicos, en general, como sabemos, no pueden ser modificados, suspendidos, anulados o revocados arbitrariamente. En consecuencia, solo pueden ser modificados o revocados en determinadas circunstancias y condiciones, mediante un acto unilateral que, desde luego, debe estar en conformidad con el derecho internacional. El acto convencional puede ser modificado o revisado, incluso terminado, de mutuo acuerdo entre las partes, principio general recogido en el artículo 57 de la Convención de Viena de 1969.

La terminación de un tratado puede ocurrir por circunstancias no previstas en él: su violación por una de las partes, imposibilidad de ejecución, por un conflicto armado o por el surgimiento de una norma de derecho internacional general. La denuncia de un tratado mediante un acto unilateral formal también es posible cuando está autorizado por el tratado o se funda en el acuerdo de todas las partes o por el surgimiento de determinadas circunstancias.

El acto unilateral tampoco es inmutable; puede ser objeto de modificación o de revocación. Lo importante es precisar si ese cambio puede producirse también de manera unilateral y, de ser posible, en qué condiciones y circunstancias.

La diversidad de actos unilaterales ya referida incide en la consideración de esta cuestión. Hemos dicho que los actos unilaterales son distintos. Mediante algunas declaraciones se asumen obligaciones, según sus propios términos y la intención del autor; en otros casos, se renuncia a un derecho o a una pretensión o se protesta ante una situación, no implicando en estos casos la asunción de obligaciones por parte del Estado autor. De manera que la modi-

48 Citado en *Disputa fronteriza* (Burkina Faso/Mali), CIJ, Fallo, 22/12/1986, parág. 40.

49 *Ibid.*

50 *Ibid.*

51 *Actividades Armadas sobre el territorio del Congo* (Nueva solicitud: 2002) (República Democrática del Congo c. Ruanda), CIJ, Fallo, 03/02/2006, parág. 50.

cación del acto, es decir, su revisión, terminación, suspensión o revocación, depende en alguna medida del tipo de acto de que se trate.

En efecto, las situaciones son distintas en función del tipo de acto. Si un Estado promete adoptar una conducta determinada en el futuro y en el o los destinatarios ha surgido una expectativa y lo han considerado como vinculante para ese Estado, la revocación no podría ser unilateralmente arbitraria. Un acto unilateral en ese sentido sería contrario a derecho y comprometería incluso la responsabilidad internacional del Estado. Sin embargo, si un Estado se limita a protestar ante otro por una determinada situación o pretensión, esta protesta no crea derechos a favor de terceros y las expectativas son, entonces, distintas. En estos casos, la revocación o la modificación, en términos generales, responde a criterios diferentes y parece posible en forma unilateral.

Un reconocimiento de Estado o de gobierno –al menos *de jure*– sería en principio irrevocable, pero la práctica muestra lo contrario. El Gobierno de Emiratos Árabes y el de Arabia Saudita anularon el acto por el cual habían reconocido al Gobierno talibán de Afganistán. El reconocimiento de la República de China por algunos países, como Costa Rica, que solo reconocían a Taiwán, refleja que el acto de reconocimiento hacia Taiwán ha sido revocado. Podemos decir, entonces, que estamos ante un acto de revocación implícito.

La doctrina no es unánime en relación con la posibilidad de que el Estado autor modifique o revoque unilateralmente un acto unilateral. Tampoco los miembros de la CDI se pronunciaron de manera uniforme⁵².

La conclusión es que un acto unilateral puede ser revocado, pero, como dijimos, dentro de ciertos límites. Para algunos, el autor de un compromiso unilateral puede revocarlo o modificarlo si, previamente, recibe el consentimiento expreso de todos sus destinatarios. Es una situación hipotética factible cuando el destinatario es determinado. Pero, a veces, cuando estamos ante compromisos *erga omnes*, como sería el caso de los compromisos adquiridos por Francia por sus declaraciones unilaterales, la situación es mucho más compleja.

Una declaración puede, también, tener un compromiso limitado en el tiempo, por ejemplo, una acción de cooperación traducida en el hipotético caso del compromiso de enviar personal técnico por un tiempo a otro Estado, una ayuda o una acción de cooperación temporal.

La CDI, después de haber examinado el tema, concluyó con la adopción de un principio general, que queda establecido en la Directriz 9, adoptada por la CDI en 2006, que establece que "una declaración unilateral que ha creado obligaciones jurídicas para el Estado que hace la declaración no puede ser revocada arbitrariamente".

Un acto puede ser modificado o revocado si ello está establecido de manera expresa en la declaración o si se deduce con claridad de ella tal posibilidad, o si el o los destinatarios del acto no adquieren el o los derechos concedidos por el acto, o bien si hay una imposibilidad para ejecutarlo o ha ocurrido un cambio de circunstancias que impiden su ejecución.

Finalmente, un acto de revocación no sería considerado arbitrario si ha ocurrido un cambio fundamental en las circunstancias, lo que proviene del régimen de Viena que regula, en el artículo 62 de la Convención de 1969, las condiciones para que un Estado parte pueda alegar el cambio de circunstancias.

De manera que, si bien un acto puede ser formulado unilateralmente por un Estado, de conformidad con el derecho internacional, no puede ser revocado en todos los casos en forma unilateral y arbitraria.

CAPÍTULO 12

ACTOS UNILATERALES DEL ESTADO (SEGUNDA PARTE)

AQUIESCENCIA Y ESTOPPEL

1. La aquiescencia

1.1. Concepto y requisitos

La aquiescencia es un concepto que proviene del derecho romano e históricamente se ha manifestado bajo la máxima *qui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac potuisset* (el que calla parece que consiente si pudiera y debiera hablar). Opera calificando la inacción y genera efectos jurídicos en las relaciones jurídicas.

En la actualidad, la aquiescencia es un instituto consolidado en el derecho internacional público. Su principal consecuencia es provocar la pérdida de un derecho sustancial o del derecho a presentar un reclamo.

La doctrina sobre la aquiescencia se encuentra arraigada en los conceptos generales de buena fe y equidad y puede aplicarse a diversas relaciones de derecho internacional en las que intervengan distintos sujetos de este derecho¹. No obstante, en este capítulo, abordaremos su análisis desde la perspectiva de las relaciones interestatales.

Es posible definirla como aquella situación donde "la inacción en representación de un Estado puede dar lugar a la pérdida de un derecho o de un reclamo si, bajo tales circunstancias, se hubiere esperado que el Estado desarrolle algún tipo de actividad"².

Por su parte, quien reclama debe demostrar que el otro Estado no presentó su reclamo con anterioridad y, así, implícitamente aceptó su extinción³. Si un Estado, ante un reclamo o comportamiento de otro Estado, guarda silencio (o no protesta) estará consintiendo esa nueva situación.

La doctrina de la aquiescencia ha cumplido un rol destacado en la resolución de disputas territoriales, como veremos más adelante. Ante la inacción por parte de un Estado frente a la realización de actos de soberanía por otro, los tribunales determinaron que el derecho o pretensión jurídica del primer Estado se había extinguido.

52 Crawford, James, *op. cit.*, p. 416 y ss; Remiro Brotons, Antonio, *Derecho Internacional*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007, p. 308.

1 Tams, Christian, "Waiver, Acquiescence, and Extinctive Prescription", in *The Law of International Responsibility*, Crawford, James; Pellet, Alain, y Olleson, Simon (eds.), Oxford University Press, Oxford, 2010, p. 1048.
2 Marques Antunes, Nuno Sérgio, "Acquiescence" (2009), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>, párr. 2 (traducción libre).
3 Tams, Christian, *op. cit.*, p. 1048.

El Estado que incurre en aquiescencia deberá aceptar las consecuencias jurídicas que su conducta genera. Sin embargo, para que la aquiescencia pueda producir efectos jurídicos es necesario que cumpla determinados requisitos. Estos son:

1. Ausencia de reclamo. El silencio o la pasividad son las conductas que generan aquiescencia. Sin perjuicio de ello, la falta de reclamación también puede provenir de ciertas formas de conductas positivas por parte del Estado⁴.
2. La ausencia de reclamo debe prolongarse durante un determinado período de tiempo. Cuanto más extenso ese período sea, más factible será determinar que implica la renuncia a sus derechos por parte del Estado. Cabe señalar que el derecho internacional no ha establecido ningún plazo y que, para determinar el efecto de la inacción en una relación jurídica determinada, requerirá el análisis particular de cada caso⁵.
3. La ausencia de reclamo debe haberse puesto de manifiesto en circunstancias en las que se hubiera requerido acción por parte del Estado.
4. La aquiescencia solo puede afectar los derechos de aquel Estado que incurre en ella y no los de terceros Estados. Ello constituye el corolario de la máxima *nemo plus dare quam ipse habet*⁶.
5. Atribución: Solo los representantes del Estado pueden provocar que un Estado incurra en aquiescencia⁷.
6. La inacción del Estado que incurre en aquiescencia debe ser consecuencia de su libre voluntad y no debe haber estado viciada.
7. La aquiescencia no podrá avalar situaciones en las que se han quebrantado obligaciones fundamentales⁸.

1.2. Relación entre la aquiescencia y la prescripción adquisitiva

La prescripción adquisitiva ha sido considerada históricamente como uno de los modos derivados de adquisición de territorios reconocidos por el derecho internacional. Como se verá en uno de los capítulos siguientes de esta obra, la prescripción adquisitiva permite que un Estado consolide un título putativo de soberanía sobre un territorio determinado y remueve los defectos que dicho título posee provenientes de un hecho de usurpación. La relación entre la prescripción adquisitiva y la aquiescencia es de carácter complementario. Para que opere la prescripción adquisitiva, el Estado cuyos derechos fueron menoscabados debió haber incurrido en aquiescencia⁹.

La prescripción adquisitiva permite que un Estado adquiera derechos de soberanía sobre un territorio que antes se hallaba bajo la soberanía de otro Estado. El derecho permite que el nuevo ocupante adquiera la soberanía frente al descuido del antiguo titular del dominio de sus derechos como Estado soberano. Para consolidar este nuevo derecho se requiere que el ejercicio de competencias soberanas se realice de manera continua y no perturbada durante un período de tiempo suficiente.

4 En el caso del *Templo de Preah Vihear*, el reclamo de soberanía de Tailandia sobre cierta porción del territorio resultó improcedente debido a que, *inter alia*, había aceptado y utilizado sin protestar ciertos mapas fronterizos que contradecían su pretensión; *Templo de Preah Vihear* (Camboya c. Tailandia), CIJ, Fallo, 15/06/1962, parágs. 23, 24.

5 En el caso *Grisbadarna*, Noruega no hizo valer sus derechos sobre ciertos bancos de pesca en los cuales la otra parte (Suecia) había realizado claras acciones soberanas. Omitió presentar una protesta frente a un claro acto de soberanía por parte de Suecia. La falta de acción de Noruega dio lugar a la aquiescencia, aun cuando el período dentro del cual se desarrolló la inacción fue relativamente corto; *Grisbadarna* (Noruega c. Suecia), Sentencia arbitral, 23/10/1909, R.I.A.A., vol. xi, pp. 121-140.

6 Suy, Eric, *Les actes juridiques unilatéraux en droit international public*, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, París, 1962, p. 166.

7 En el caso del *Templo de Preah Vihear*, la conducta que provocó la aquiescencia de Tailandia fue atribuida a un funcionario de menor rango; *Templo de Preah Vihear*, doc. cit., p. 28.

8 Tams, Christian, op. cit., p. 1044.

9 Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, Oxford, 6.ª edic., 2003, p. 145.

La prescripción adquisitiva sanea un título imperfecto, convirtiéndolo en perfecto. Se basa en la buena fe y en el abandono presunto y voluntario de los derechos por parte de quien pierde el derecho y la necesidad de preservar el orden y la estabilidad.

La aquiescencia y la prescripción adquisitiva son dos conceptos que operan como *alter egos*. La existencia de aquiescencia se erige como el presupuesto fáctico necesario para que opere la prescripción adquisitiva. Transcurrido cierto lapso de tiempo (que será determinado en cada caso en particular), todo acto de ocupación ilegal devendrá legal y todo acto de protesta será inoponible debido a la aquiescencia previa del Estado que no ejerció sus derechos oportunamente¹⁰.

Algunos doctrinarios sostienen que, si uno de los Estados reclamantes incurre en aquiescencia, no sería de aplicación la doctrina de la prescripción adquisitiva. En estos casos, la aquiescencia per se consolidaría un derecho de soberanía en cabeza del Estado que la invoca¹¹. Esta parece haber sido la doctrina receptada en el caso de la *Isla de Palmas*. El árbitro del caso -Max Huber-, al analizar si era Holanda o Estados Unidos quien ostentaba un *mejor título*, evitó toda referencia al instituto de la prescripción adquisitiva. Brownlie señala que el árbitro Huber implícitamente descartó la aplicación de la prescripción adquisitiva porque en el territorio bajo disputa existía una determinada actividad de otro Estado competidor que también reclamaba su soberanía. El árbitro optó por aplicar el criterio de la "ocupación efectiva" del territorio¹².

1.3. Relación entre la aquiescencia y la prescripción liberatoria

La prescripción extintiva o liberatoria es un instituto reconocido por el derecho internacional cuyo principal efecto es producir la pérdida del derecho a invocar la responsabilidad internacional de un Estado. La doctrina de la prescripción extintiva está basada en la idea de que el transcurso del tiempo lleva a la eliminación de un reclamo jurídico. Se ha afianzado a través de las distintas decisiones jurisprudenciales que fueron receptándola como un modo de extinción de los reclamos.

El derecho internacional general no ha fijado un plazo general sobre el que opera la prescripción extintiva. No obstante, cabe reiterar lo manifestado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de *Ciertas tierras fosfáticas en Naurú*: la demora en presentar un reclamo por parte de un Estado puede llegar a producir la extinción de su derecho de incoar su ejercicio¹³. Un Estado que intente valer la prescripción extintiva deberá establecer que la demora fue atribuible al reclamante y que este último pudo en todo momento articular el reclamo, y si no lo hizo, fue porque libremente decidió no hacerlo¹⁴.

La prescripción extintiva exige la concurrencia de dos elementos para que pueda producir efectos jurídicos: 1) el paso del tiempo sin que se ejerza el derecho, tomando en consideración todas las circunstancias de un caso en particular y cada caso considerado de manera inde-

10 Existen numerosas decisiones jurisdiccionales sobre cuestiones territoriales que se han referido al requisito de la ocupación incontestada como uno de los elementos para que opere la prescripción adquisitiva de un Estado y aun sin referirse explícitamente a ella. En ellos la aquiescencia ha sido un elemento de análisis fáctico a los fines de determinar si se ha consolidado el derecho de dominio sobre un determinado territorio. Al respecto ver: *Isla de Palmas* (EE.UU./Países Bajos), Sentencia arbitral, 04/04/1928, R.I.A.A., vol. ii, pp. 84-86; *Estaduto jurídico de Groenlandia Oriental* (Noruega c. Dinamarca), CPJ, Fallo, 05/04/1933, CPJ Serie A/B, n.º 53, p. 48; *Caso de los islotes de Minquiers y Ecrehos* (Francia/Reino Unido), CIJ, Fallo, 17/11/1953, ICJ Reports 1953, p. 47; *Soberanía sobre ciertas parcelas Fronterizas* (Bélgica/Países Bajos), CIJ, Fallo, 20/08/1959, ICJ Reports 1959, p. 28.

11 Schwarzenberger, Georg, *International Law*, London Stevens, Londres, 3.ª edic., 1957, p. 307.

12 Brownlie, Ian, op. cit., pp. 145-146.

13 Ver *Ciertas tierras fosfáticas en Naurú* (Nauru c. Australia), CIJ, Fallo, 26/06/1992, ICJ Reports 1992, pp. 240, 253.

14 Tams, Christian, op. cit., p. 1043.

pendiente¹⁵; 2) que el paso del tiempo haya colocado a quien resulta ser demandado ante una situación de desventaja¹⁶.

En cuanto a la relación entre prescripción extintiva y aquiescencia, no resulta fácil trazar una diferencia entre ambos conceptos. Aquiescencia y prescripción extintiva operan en planos jurídicos diferentes, aunque complementarios. La aquiescencia extingue el derecho del reclamante. Este es el efecto jurídico que produce la inacción de quien debió haber realizado una determinada conducta y no lo hizo. Por el contrario, la prescripción extintiva opera en un doble plano: procesal y sustancial. Requiere que esa inacción se haya prolongado durante un determinado período de tiempo y que haya perjudicado al demandado contra el cual pretende hacerse valer el reclamo.

1.4. Aplicación jurisprudencial

Varios tribunales internacionales han considerado la aquiescencia y los efectos jurídicos que podría acarrear en el marco de las controversias que dirimían. He aquí algunos ejemplos.

En el caso del *Templo de Preah Vihear*, la CIJ consideró que el Reino de Siam, hoy Tailandia, había consentido la delimitación establecida en un mapa confeccionado por la Comisión Mixta de Límites de Siam y Camboya a principios del siglo xx. Debido a la falta del reclamo de Tailandia sobre la validez de los mapas, entre los años 1908 (fecha de confección de tales mapas) y 1958 (fecha en la que Tailandia objetó su validez) quedó configurada su aquiescencia. De esta manera, una situación jurídica *de facto*, debido a su conducta, devino *de iure*. La CIJ otorgó efectos jurídicos al silencio de Tailandia durante cincuenta años y convalidó el estado de cosas consolidado durante ese tiempo¹⁷.

Por su parte, en el caso de *Ciertas tierras fosfáticas en Naurú*, la CIJ estableció que, aun ante la ausencia de cualquier cláusula de un tratado, la demora del demandante podía convertir al reclamo en inadmisibile¹⁸.

En el caso sobre la *Frontera de Alaska (Alaska Boundary)* el tribunal arbitral señaló que la posesión continua del territorio en disputa sin que otros Estados protestasen consolidaba el derecho territorial de Rusia¹⁹. En otras palabras, la aquiescencia de las partes afianzó un derecho territorial en cabeza de Rusia.

La CIJ, en el caso de las *Pesquerías*, sostuvo que el Reino Unido debería haber manifestado su disconformidad con el sistema utilizado por Noruega para fijar la línea de más baja marea a lo largo del Mar del Norte con anterioridad al momento en que lo hizo. En consecuencia, al haberse demorado sesenta años en hacerlo desde que tomó conocimiento del sistema de líneas de base implementado por Noruega, su aquiescencia quedó materializada. Su silencio, en consecuencia, produjo consecuencias jurídicas²⁰.

En el caso relativo a *Elettronica Sicula SpA*, los Estados Unidos alegaron que Italia violaba el tratado suscrito entre ambos países al impedir que una sociedad estadounidense accionista de otra sociedad italiana pudiera pagar dividendos. Conforme a los Estados Unidos, la sociedad estadounidense había agotado todos los remedios previstos en la legislación italiana para lograr su cometido, y la defensa presentada por Italia respecto de la falta de agotamiento de los recursos internos ante los tribunales italianos era extemporánea, dado que con su silencio Italia había prestado su aquiescencia respecto del agotamiento de tales recursos invocado por los Estados Unidos. La CIJ, no obstante, consideró que, aun cuando el silencio podía producir la aquiescencia, en el presente caso no se había materializado el prerrequisito: la obliga-

ción de Italia de pronunciarse sobre el agotamiento de los referidos recursos. Por ello, la mera ausencia de mención sobre tales circunstancias no generaba aquiescencia por parte de Italia²¹.

Cabe señalar que en otras controversias la CIJ concluyó que la aquiescencia de un Estado no generaba por sí sola efectos jurídicos. En el caso *Jan Mayen*, Dinamarca argumentó que Groenlandia estaba autorizada a establecer una zona de pesca de doscientas millas marinas desde su línea de base. Noruega, por su parte, sostuvo que el límite exterior de esa zona de pesca estaba determinado por una línea media divisoria de las costas relevantes; Dinamarca conocía la posición de Noruega al respecto y que su silencio había generado la extinción de la posibilidad de presentar un reclamo. La CIJ concluyó que el silencio danés no generaba aquiescencia debido a que Dinamarca había optado por actuar así con el objetivo de no agravar la situación pendiente de delimitación definitiva. En síntesis, para la CIJ, el silencio de Dinamarca se encontraba justificado y no generaba efectos jurídicos²².

Asimismo, en el caso relativo a la *Controversia territorial (Libia c. Chad)*, en su opinión separada, el juez Ajibola señaló que la falta de solicitud de invalidez por parte de Libia del Tratado de Amistad y Buena Vecindad suscrito con Chad no generaba efectos jurídicos, dado que su silencio desde la firma del tratado (1955) no militaba en contra del reclamo libio. El uso del término "militaba" parece indicar que, aun cuando el silencio puede llegar a tener una influencia, no posee per se un peso jurídico concluyente²³.

2. El estoppel

2.1. Concepto y requisitos

El *estoppel* es una excepción de fondo receptada en el derecho internacional por la jurisprudencia internacional. Permite que un sujeto de derecho internacional rechace un reclamo formulado por un Estado que, con su conducta anterior, dio lugar a que la otra parte en la controversia presuma su consentimiento con determinados hechos o situaciones que ahora considera diferentes o niegue su existencia²⁴.

El *estoppel* impide que un Estado presente un reclamo si, debido a su conducta previa, las declaraciones u otras manifestaciones de voluntad: 1) han inducido a otro Estado a creer, de buena fe, que el derecho a reclamar no iba a ser ejercido, o 2) que el ejercicio de ese derecho no iba a ser invocado en detrimento del Estado que se encuentra particularmente perjudicado.

El profesor Pecourt García destaca que son tres los elementos que configuran la noción de *estoppel*: 1) una situación creada por la actitud de un Estado (actitud primaria); 2) una conducta seguida por otro Estado (actitud secundaria) basada directamente en la primera conducta; 3) la imposibilidad por parte del Estado que adoptó la actitud primaria de hacer alegaciones contra esta o de manifestarse en sentido contrario²⁵.

El *estoppel* impide a un Estado que ha incurrido en determinados actos estatales (incluso actos de abstención o silencio que generan una situación de aquiescencia) poder volver sobre sus propios actos cuando con estos se han lesionado derechos o expectativas de otros Estados que se perfeccionaron debido al comportamiento primario del Estado. Actúa estableciendo un límite, una restricción, y cumple una función de privación o pérdida de derechos. No crea nuevas obligaciones internacionales; por el contrario, las extingue.

El instituto del *estoppel* recepta de esta manera la doctrina de los actos propios de los derechos hispánicos o de la *forclusion* del derecho francés.

15 Ver *Ambatielos* (Grecia c. Reino Unido), Sentencia arbitral, 06/03/1956, *International Law Reports*, vol. 23, pp. 314-317.

16 Hobér, Kaj, *Extinctive Prescription and Applicable Law in Interstate Arbitration*, Iustus Forlag, Uppsala, 2001, pp. 286, 301-304.

17 *Templo de Preah Vihear*, doc. cit., p. 6.

18 Ver *Ciertas tierras fosfáticas en Naurú* (Nauru c. Australia), doc. cit., pp. 240, 253.

19 Ver *Frontera de Alaska* (Estados Unidos/Alaska), Sentencia arbitral, 20/10/1903, *R.I.A.A.*, vol. 15, p. 525, parág. 5.

20 *Pesquerías* (Reino Unido c. Noruega), CIJ, Fallo, 18/12/1951, *ICJ Reports 1951*, p. 140.

21 *Elettronica Sicula SpA* (Estados Unidos c. Italia), CIJ, Fallo, 20/07/1989, parág. 54.

22 *Delimitación marítima de la zona situada entre Groenlandia y Jan Mayen* (Dinamarca c. Noruega), CIJ, Fallo, 14/08/1993, parág. 35.

23 *Controversia Territorial* (Libia c. Chad), CIJ, Fallo, 03/02/1994, Opinión Separada del juez Ajibola, parág. 109.

24 Moncayo, Guillermo; Vinuesa, Radl y Gutierrez Posee, Hortensia, *Derecho Internacional Público*, t. 1, Zava-
lia, Buenos Aires, 1977, p. 129.

25 Pecourt García, Enrique, "El principio de *estoppel* en derecho internacional público", *Revista española de
Derecho Internacional*, vol. xv (1962), p. 97 y ss.

Finalmente, cabe señalar que un número considerable de autores considera que el *estoppel* es un principio general del derecho que descansa en otro principio de aplicación entre las partes: el de la buena fe²⁶.

2.2. Relación entre el *estoppel* y la aquiescencia

Ante una situación en la que se configura el *estoppel*, un Estado se encuentra impedido de incoar un reclamo, debido a que su conducta previa, declaraciones u otras manifestaciones de voluntad han inducido a otro Estado a creer, de buena fe, que el derecho no sería ejercido y a no considerar que tales circunstancias perjudicarían los derechos del Estado contra el cual se invoca un nuevo estado de cosas. De esta forma, el Estado que modifica su conducta no está consintiendo la pérdida de ninguno de sus derechos, sino que, debido a su conducta anterior, se ve impedido de invocar su reclamo.

Por el contrario, en el caso de aquiescencia, el Estado reclamante ha aceptado implícitamente haber perdido el derecho a reclamar; tal aceptación proviene de su conducta inequívoca en tal sentido. El Estado acepta, entonces, colocarse en esta nueva situación²⁷.

Sin embargo, esta distinción teórica resulta muy difícil de aplicar en la práctica, dado que existe una delgada línea donde ambos conceptos son de utilidad práctica para evaluar las consecuencias jurídicas de la acción e inacción por parte de un Estado²⁸.

2.3. Aplicación jurisprudencial

Podemos citar algunos de los precedentes jurisprudenciales en los cuales diversos tribunales internacionales han considerado la aplicación del *estoppel* al resolver controversias.

La Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso de los *Empréstitos serbios y brasileños* se planteó si, debido a la conducta de los ciudadanos franceses, tenedores de los títulos de la deuda, se había perdido el derecho a obtener el pago de la deuda en valor oro. En aquella ocasión, la Corte entendió que la aplicación del principio del *estoppel* carecía de fundamento legal, dado que los tenedores de títulos no habían realizado declaraciones claras e inequívocas sobre las que se pudiese inferir que habían renunciado a ejercer sus derechos de cobro de los referidos empréstitos²⁹.

El espíritu de la doctrina del *estoppel* también se encuentra presente en el asunto del *laudo arbitral emitido por el Rey de España el 23 de diciembre de 1906*. En este caso, la CIJ manifestó que Nicaragua había reconocido la validez de la sentencia y ello había quedado de manifiesto a través de las distintas declaraciones y conductas realizadas por el Estado centroamericano. De esta forma, concluyó que Nicaragua había perdido el derecho a pedir su impugnación³⁰.

En el asunto del *Estatuto Jurídico de Groenlandia Oriental*, la CPIJ concluyó que la declaración realizada por el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega en 1919 —que reconocía que Groenlandia pertenecía a Dinamarca— daba lugar a una situación de *estoppel* que precluía la invocación de un derecho contrario al reconocido en 1919, debido principalmente

a que dicha declaración había sido pronunciada de manera clara y consistente con previas declaraciones noruegas³¹.

En el caso del *Templo de Preah Vihear*, la conducta de Tailandia había formado el consentimiento de Camboya de que el Tratado de límites firmado en 1908 era válido y se encontraba vigente. Sin embargo, a partir de 1958, Tailandia invocó su nulidad por error. La CIJ entendió que Tailandia estaba impedida por su conducta anterior de invocar la invalidez del tratado. Durante cincuenta años, había creado la convicción con su conducta (su silencio) sobre un determinado estado de cosas que tanto más tarde pretendía rechazar e ignorar³².

Años más tarde, en la fase jurisdiccional del caso de las *Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*, la CIJ entendió que "la constante aquiescencia" de Nicaragua en varias de sus declaraciones públicas produjo que la Declaración de 1929 sobre la aceptación de la jurisdicción de la CIJ sea de aplicación obligatoria para este país y que ello constituya un modo válido de aceptación de reconocer la jurisdicción obligatoria de la Corte bajo el artículo 36(2) de su Estatuto³³.

En el caso relativo a los *Ensayos Nucleares*, Australia solicitó a la CIJ que declarase que los ensayos nucleares atmosféricos realizados por Francia en el océano Pacífico Sur eran ilegales. Antes de que la CIJ pudiera intervenir en la controversia, Francia unilateralmente declaró que los ensayos nucleares pendientes iban a ser los últimos. La CIJ concluyó que las declaraciones de Francia habían dado lugar al *estoppel*³⁴.

La CIJ también se refirió a la necesidad de que exista un perjuicio concreto para que pueda invocarse *estoppel*. En el caso relativo a la *Controversia fronteriza terrestre, insular y marítima* entre El Salvador y Honduras, la Corte señaló que, para que exista *estoppel*, una de las partes debe demostrar el perjuicio o la ventaja que ha obtenido quien ha provocado dicho perjuicio³⁵.

En el caso relativo a la *Frontera Terrestre y Marítima entre el Camerún y Nigeria*, la CIJ nuevamente volvió a afirmar que el *estoppel* emerge solo cuando un Estado, confiando en una situación representada por otro Estado, modifica su conducta en su propio perjuicio o es perjudicado de alguna manera³⁶.

El perjuicio del Estado que invoca el *estoppel* ha sido señalado como uno de los requisitos necesarios por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en la *Disputa concerniente a la delimitación de la frontera marítima entre Bangladesh y Myanmar*. En dicha controversia, Bangladesh alegó que Myanmar se había beneficiado de un acuerdo celebrado entre ambos Estados en 1974, según el cual se habían establecido los límites marítimos estables entre ambos Estados y asimismo otorgado el derecho de paso libre a Myanmar a través de las aguas territoriales de Bangladesh. Como consecuencia de ello, Bangladesh sostuvo que la posición de Myanmar de negar efectos y validez jurídica al citado Acuerdo de 1974 configuraba una situación de *estoppel*³⁷. El Tribunal rechazó la existencia de *estoppel* alegada por Bangladesh sobre la base de que dicho Estado no había demostrado de manera conclusiva que ambos países hubieran administrado sus aguas de conformidad con los límites establecidos en el Acuerdo de 1974. Por lo tanto, concluyó que Myanmar no había provocado un cambio de postura en detrimento de Bangladesh ni que este último Estado había sufrido algún perjuicio como consecuencia de haber considerado la conducta de Myanmar³⁸.

26 Así se han expresado los jueces Alfaro y Fitzmaurice en el caso del *Templo de Preah Vihear*, doc. cit., pp. 39-51, 61-65; Lauterpacht, Hersch, *The Development of International Law by the International Court*, Textbook Publishers, Londres, 1958, pp. 168-172; Report on the International Law Commission on the Law of Treaties, *Yearbook of the International Law Commission* (1963), pp. 212-213.

27 *Templo de Preah Vihear*, doc. cit., Opinión Separada del juez Fitzmaurice, p. 6, parágs. 82-83.

28 Sinclair, Ian, "Estoppel and Acquiescence", en *Fifty Years of the International Court of Justice*, Lowe, Vaughan y Fitzmaurice, Malgosa, (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, 1996, pp. 104-105.

29 *Empréstitos serbios y brasileños* (Francia c. Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos), CPIJ, Fallo, 12/07/1929, *CPIJ Serie A*, n.º 20 y 21, p. 38 y ss.

30 *Laudo arbitral emitido por el Rey de España el 21 de diciembre de 1906* (Honduras c. Nicaragua), CIJ, Fallo, 18/11/1960, *ICJ Reports* 1960, p. 213.

31 *Estatuto jurídico de Groenlandia Oriental* (Dinamarca c. Noruega), doc. cit., p. 73.

32 *Templo de Preah Vihear*, doc. cit., p. 30.

33 *Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* (Nicaragua c. Estados Unidos), CIJ, Fallo, 18/11/1984, *ICJ Reports* 1984, pp. 392, 411-413, parágs. 43-47; pp. 413-415, parágs. 48-51.

34 *Ensayos Nucleares* (Australia c. Francia), CIJ, Fallo, 20/12/1974, *ICJ Reports* 1974, pp. 18, 20.

35 *Controversia fronteriza terrestre, insular y marítima* (El Salvador/Honduras), CIJ, Solicitud de Permiso para Intervenir, Fallo, 13/09/1990, *ICJ Reports* 1990, p. 118.

36 *Frontera terrestre y marítima entre el Camerún y Nigeria* (Camerún c. Nigeria), CIJ, Objeciones Preliminares, Fallo, 11/06/1998, *ICJ Reports* 1998, p. 308.

37 *Disputa concerniente a la delimitación de la frontera marítima entre Bangladesh y Myanmar en la Bahía de Bengala* (Bangladesh/Myanmar), TIDM, Fallo, 14/03/2012, parágs. 119-120.

38 *Ibid.*, parág. 125.

3. El *estoppel* y la aquiescencia en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados

Como se vio en el capítulo 8, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) incorpora los institutos de la aquiescencia y del *estoppel* en las disposiciones generales de la sección 1 de la parte v referida a la "Nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los tratados". En su artículo 45, párrafo b, la citada convención establece que un Estado pierde el derecho de alegar una causa de nulidad de un tratado o de terminarlo, retirarse de él o suspender su aplicación (conforme a las causales de nulidad, suspensión y terminación taxativamente establecidas en los artículos 46 a 50, 60 y 62) si, luego de haber tenido conocimiento de la existencia de un hecho que pudiese dar origen a la presencia de una causal de nulidad, suspensión o terminación, se hubiese comportado de tal manera que deba considerarse que prestó su aquiescencia a la validez del tratado o a su continuación en vigor o en aplicación.

El citado artículo 45 vincula íntimamente el *estoppel* a la aquiescencia. La Convención de Viena ha articulado la aplicación de ambos conceptos exclusivamente en el contexto de la nulidad, suspensión y terminación, de manera tal que la conducta de aquel Estado que ha incurrido en aquiescencia pueda ser tomada en consideración por otro Estado como presupuesto fáctico para invocar la defensa del *estoppel*.

CAPÍTULO 13

ACTOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

Lucas E. Barreiros*

1. Introducción

El siglo xx ha sido testigo de un crecimiento notable¹ en la cantidad de organismos internacionales creados por los Estados como un foro para la cooperación entre sí y un vehículo para la consecución de objetivos comunes². La expansión no ha tenido lugar solamente en el número de organismos internacionales existentes, sino también en su ámbito material de actuación³, así como en sus competencias, atribuciones y en su nivel de actividad⁴.

Sin perjuicio de esta realidad, si se analiza la enumeración de fuentes del derecho internacional público establecida en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, se observa que los actos de las organizaciones internacionales no forman parte de ella.

La teoría general sobre las fuentes del derecho internacional sigue concentrándose en los tratados, la costumbre y los principios generales de derecho como los modos válidos de producción de normas en derecho internacional; no siempre reconoce autonomía a los actos emanados de los órganos o instituciones de los organismos internacionales. Por el contrario, los actos de organismos internacionales solo son tenidos en cuenta en la medida en que pueden

* Este trabajo está dedicado a la memoria de Alejandro Turyn, querido amigo y colega, quien me acompañara de forma determinante en mis primeros pasos en esta disciplina. Agradezco la asistencia en la investigación y los comentarios de María Victoria Gama y Florencia Saulino.

1 La variabilidad en la definición de la categoría "organismo internacional" y las distintas perspectivas sobre qué entes efectivamente pueden considerarse como tales no permiten contar con una estadística unificada. Sin embargo, una evaluación conservadora identifica menos de cincuenta organismos internacionales antes de la Primera Guerra Mundial, menos de ochenta antes de la Segunda Guerra Mundial y más de trescientos a comienzos del siglo xxi. Véase, Díez de Velasco, Manuel, *Las Organizaciones Internacionales*, Tecnos, Madrid, 18.ª edic., 2003, p. 42.

2 Abbott, Kenneth W. y Snidal, Duncan, "Why States Act Through Formal International Organizations", *Journal of Conflict Resolution*, vol. 42 (1998), n.º 1, pp. 3-5, 10; Amerasinghe, Chittaranjan F., *Principles of the Institutional Law of International Organizations*, Cambridge University Press, Cambridge, 2.ª edic., 2003, p. 8.

3 Las organizaciones internacionales, que en su estado embrionario tenían competencia en general sobre cuestiones de cooperación técnica en ámbitos limitados —como la Comisión Central para la Navegación del Rin, creada en 1815 por el Congreso de Viena—, fueron ampliando sus competencias y sus modalidades de acción, las que hoy incluyen, entre otras, el mantenimiento de la paz y la reconstrucción en Estados devastados por la guerra a través de Operaciones de Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz, la asistencia financiera y técnica para combatir la pobreza y alcanzar un desarrollo sustentable (Banco Mundial), la asistencia a refugiados y otros individuos en situación de vulnerabilidad (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), el desarrollo de políticas de salud y de asistencia para los Estados (Organización Mundial de la Salud), la ayuda a Estados para lograr un cierto grado de desarrollo (Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), la elaboración y administración de normas que rigen el comercio internacional y tienden a su progresiva liberalización (Organización Mundial del Comercio) y la protección de la propiedad intelectual (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), entre otras.

4 Abbott, Kenneth W. y Snidal, Duncan, *op. cit.*, p. 10.